법학연구(연세대학교 법학연구원)
제36권 제2호 (2026년 6월) 301~350면

Yonsei Law Review
Vol. 36 No. 2 (June 2026) pp. 301~350
DOI https://doi.org/10.21717/ylr.36.2.8

# 재판소원이 제기된 확정판결의 효력에 관한 시론

## — 확정판결을 중심으로 한 '유동적 확정' 개념의 제안 —

김 민 규* · 박 상 영**

◈ 목 차 ◈

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 재판소원 제도의 구조와 효력론적 긴장
1. 2026년 개정 헌법재판소법의 조문 구조
2. 판결례적 전사(前史)
3. 효력론적 긴장의 발생
Ⅲ. 확정판결의 효력과 헌법재판소 결정의 기속력
1. 확정판결의 다층적 효력
2. 헌법재판소 결정의 효력
3. 두 효력의 충돌과 효력조정론
Ⅳ. 유동적 확정의 정식화
1. 공법상 효력유지 구조와 유동적 무효의 착안
2. 유동적 확정의 정의와 법적 성질
3. 유동적 확정의 발생요건
4. 유동적 확정의 효력별 작동
5. 유동적 확정의 종료
6. 재심과의 구별: 잠재적 가능성과 절차적으로 현출된 가능성
7. 보론: 인접개념과의 구별
Ⅴ. 비교법적 시사점
1. 독일: 재판헌법소원의 효력구조
2. 미국: 보충적 시사
3. 일본: 재판소원 부재 모델과의 대조
4. 한국법의 모델적 위치
Ⅵ. 결론

# Ⅰ. 서론

확정판결은 끝난 재판이다. 당사자는 더 이상 통상적 불복절차로 그 판단을 다툴 수 없고, 법원과 당사자는 일정한 범위에서 그 판단에 구속된다. 확정판결의 권위는 바로 이 종국성(終局性)에서 나온다.[1] 그런데 2026년 개정 헌법재판소법

* 제1저자, 변호사, KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수
** 제2저자, 대학원생, 서울대학교 일반대학원 법학과, 석사과정

1) 기판력을 분쟁의 종국적·강행적 해결을 위하여 확정판결에 주어진 힘으로 설명하는 견해로 강현중, "기판력에 관한 연구",『법학논총』제19집, 국민대학교 법학연구

은 일정한 요건 아래 그 확정된 재판을 헌법소원심판의 대상으로 다시 불러낸다. 개정법은 재판소원의 대상을 '확정된 재판'으로 한정하면서도, 30일 청구기간, 지정재판부 사전심사, 가처분, 재판취소 및 법원의 다시 재판 구조를 함께 둔다. 이 조문구조는 하나의 질문을 남긴다. "그렇다면 재판소원이 제기된 확정판결은 어떤 효력상태에 놓이는가?"[2)]

재판소원은 확정 전 상소가 아니라 확정 후 헌법소송절차이므로, 그 제기만으로 형식적 확정력이 차단되지는 않는다.[3)] 이는 곧 미확정판결로 보긴 어렵다는 판단과 통상적 확정판결과 완전히 동일하게 볼 수 없는 상황이 양립하게 된다. 적법한 재판소원이 제기되고 헌법재판소법 제68조 제3항 각 호 사유의 심사가능성이 인정되면, 대상 확정판결은 헌법재판소의 제한적 심사 가능성 아래 놓인다. 가처분이 있으면 효력 또는 집행작용이 잠정 정지될 수 있고, 본안에서 인용되면 해당 재판은 취소되며 법원의 재재판(再裁判)으로 이어진다. 본고는 이 상태를 <표 1>의 정의에 의거 '유동적 확정'으로 명명하고자 한다.

<표 1> '유동적 확정' 개념의 정의 및 요건 표지

'유동적 확정'이란, ① **적법한 재판소원**, ② 헌법재판소법 제68조 제3항 **각 호 사유의 심사가능성이 인정**되는 확정재판이 ③ 형식적 확정력, 기판력 등 **구속효 및 원칙적 집행력을 유지하면서도**, ④ 헌법재판소의 가처분 또는 인용결정에 따라 그 효력작용이 잠정 정지되거나 해당 재판의 취소 및 법원의 재재판으로 재구성될 수 있는, 이른바 효력작용이 조건화된 확정상태를 말한다. 여기서 유동하는 것은 확정 그 자체가 아니라 그 확정판결의 효력작용이다.

---

소, 2007, 100-101면.

2) 헌법재판소법 제68조 제3항, 제69조 제1항 단서, 제71조의2, 제72조 제3항·제4항, 제75조 제4항; 법제처 국가법령정보센터, "헌법재판소법", 법률 제21452호, 2026. 3. 12. 일부개정·시행. 대상재판성, 30일 청구기간, 가처분, 지정재판부 사전심사 및 인용결정의 재판취소 효과는 위 각 조문에서 확인된다.

3) 상소가 재판 확정 전의 불복절차이고 그 제기로 재판의 확정이 차단된다는 설명으로는 강현중, "상소와 재심, Appeal and Retrial", 『법학논총』 제18집, 국민대학교 법학연구소, 2006, 40면. 재판소원이 "확정된 재판"을 대상으로 한다는 점은 헌법재판소법 제68조 제3항, 그 청구기간이 확정일부터 기산된다는 점은 같은 법 제69조 제1항 단서 참조.

이 개념은 확정판결 일반에 내재하는 추상적 재심가능성과 구별된다. 확정판결도 법률이 정한 재심사유가 인정되면 다시 다투어질 수 있다. 그러나 일반 확정판결의 재심가능성은 재심사유의 발생 또는 발견과 재심청구라는 별도 사건을 기다리는 잠재적 가능성에 머무는[4] 반면 적법한 재판소원이 제기되고 심사가능성이 인정된 확정판결에서는 재판취소 가능성이 헌법재판소 절차 위에 이미 현출되어 있다. 유동적 확정은 확정판결 일반의 추상적 취소가능성을 가리키는 개념이 아니라, 효력변동 가능성이 절차적으로 현출된 확정상태를 가리키는 개념이다.[5]

본고는 헌법재판소법 제68조 제3항 각 호 가운데 제1호, 즉 법원의 재판이 헌법재판소 결정에 반하는 취지로 이루어져 기본권을 침해한 경우를 중심으로 한다. 이 유형에서는 법원 확정판결의 기판력 등 구속효와 헌법재판소 결정의 기속력이 직접 충돌할 수 있다. 제2호 적법절차 위반형과 제3호 명백한 기본권 침해형도 유동적 확정이 적용될 수 있다. 다만 공통요소는 확정재판성, 30일 청구기간, 사전심사, 가처분 및 인용효 구조이고, 제1호에 특수한 요소는 선행 헌법재판소 결정의 기속력과 법원 재판의 기판력 사이의 충돌 판단이다.[6]

---

4) 재심은 확정된 종국판결에 대한 비상불복신청이고 판결확정 후 이루어지므로 상소와 달리 확정 차단효가 없다는 설명으로는 최성호, “재심소송에 있어서 재심사유에 관한 고찰”, 『인권과 정의』 제399호, 대한변호사협회, 2009, 42면. 재심의 소 제기만으로 원판결의 확정력이나 그에 기초한 강제집행이 당연히 정지되지 않는다는 설명은 같은 글, 46면.

5) 다만 유동적 확정은 30일이라는 시간표지만으로 자동 발생하지 않는다. 30일은 먼저 확정판결을 헌법소원으로 문제 삼을 수 있는 짧은 시간적 개방기간을 설정한다. 그 기간이 지나면 제69조 제1항 단서의 청구기간을 넘긴 청구가 되어 제72조 제3항 제2호의 각하사유가 되고, 대상 확정판결은 유동적 확정상태로 진입할 수 없다. 반대로 기간 내에 적법한 재판소원이 제기되고 제72조 제3항 제4호의 명백한 청구사유 부존재를 통과할 수 있을 때, 그 시간적 개방성은 효력변동 가능성이 절차적으로 현출된 상태로 전환된다. 본고의 심사가능성은 인용가능성의 선취가 아니라, 그 최소한의 본안관련성을 뜻한다. 헌법소원 적법요건 심사와 본안판단의 증명책임 구별에 관하여는 김하열, “헌법재판의 증명책임”, 『헌법재판연구』 제8권 제1호, 헌법재판연구원, 2021, 312-313면, 325-326면.

6) 이에 대해 헌법 제111조 제1항 제5호에서 헌법소원제도의 구체적 형성을 입법자에게 위임하고 있다고 하더라도 입법자는 헌법이 예정하는 분리통제형 사법구조에 적합한 헌법소원제도 즉 법원의 재판을 포함한 모든 처분적 공권력작용을 헌법소원의 대상으로 하도록 법률을 제정하여야 하고, 헌법재판소를 비롯한 사법기관은 이

이하에서는 먼저 개정 헌법재판소법의 조문구조와 1997년·2022년 판례법적 전사(前史)를 검토한다. 이어 확정판결의 효력과 헌법재판소 결정의 기속력을 효력층별로 정리하고, 이를 토대로 유동적 확정의 정의, 발생요건, 효력별 작동, 종료 및 재심과의 구별을 정식화한다. 마지막으로 비교법적 시사를 검토한 뒤, 결론에서 본고의 의의와 한계를 밝힌다.

## Ⅱ. 재판소원 제도의 구조와 효력론적 긴장

### 1. 2026년 개정 헌법재판소법의 조문구조

개정 헌법재판소법은 법원의 재판에 대한 헌법소원심판, 이른바 재판소원을 명문으로 인정하였다. 그러나 그 방식은 전면적 개방이 아닌 제한적 허용으로, 대상·청구사유·기간·사전심사·가처분·인용효를 각각 다른 조문에 나누어 둠으로써 재판소원의 실효성과 확정판결의 안정성을 함께 조정하고 있다.

<표 2> 개정 헌법재판소법 조문 <신설 2026. 3. 12.>[7]

| |
|---|
| 제68조(청구 사유) ③ 제1항에 따라 청구된 헌법소원심판 중 법원의 재판에 대한 헌법소원심판은 ***(1)확정된 재판***을 그 대상으로 하며, ***(2)다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한정하여*** 청구할 수 있다. |

런 관점에서 헌법소원제도에 관한 법률의 위헌성을 판단하여야 한다는 주장이 가능하다. 이러한 재판소원금지 조항이 헌법소원제도의 본질 및 기본권 보장구조와 충돌한다는 문제제기로는 박경철, "우리 헌법질서에서 裁判訴願禁止의 違憲性",『공법연구』 제30권 제3호, 한국공법학회, 2002, 168-172면. 본고는 그 허용론을 반복하기보다, 입법 이후 확정판결의 효력상태를 어떻게 정식화할 것인지에 논의를 한정한다. 나아가 제2호와 제3호의 세부 판단기준은 후속 연구 과제로 남긴다. 나아가 본고는 재판소원 제도의 합헌성 일반을 다시 논증하지 않는다. 헌법재판소와 대법원의 추상적 권한우열 문제도 중심 주제로 삼지 않는다. 재판소원금지 조항을 둘러싼 종전 논쟁은 중요하지만, 본고의 관심은 재판소원이 명문으로 도입된 이후의 확정판결 효력론에 있다. 다시 말해 본고의 문제는 재판소원이 제기된 확정판결의 효력상태를 어떻게 설명할 것인가이다.

1. 법원의 재판이 헌법재판소의 결정에 반하는 취지로 재판함으로써 기본권을 침해한 경우
2. 법원의 재판이 헌법과 법률에서 정한 적법한 절차를 거치지 아니함으로써 기본권을 침해한 경우
3. 법원의 재판이 헌법과 법률을 위반함으로써 기본권을 침해한 것이 명백한 경우

제69조(청구기간) ① <생 략> 다만, 다른 법률에 따른 구제절차를 거친 헌법소원의 심판은 그 최종결정을 통지받은 날부터 30일 이내에 청구하여야 하고, 법원의 재판에 대한 헌법소원의 심판은 ***(3)그 확정일부터 30일 이내에 청구하여야*** 한다.

제71조의2(가처분) 헌법재판소가 헌법소원심판의 청구를 받은 때에는 ***(5) 직권으로 또는 청구인의 신청에 따라*** 종국결정의 선고 시까지 심판 대상이 된 공권력의 효력을 정지하는 결정을 ***할 수 있다***.

제72조(사전심사) ③ 지정재판부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 지정재판부 재판관 전원의 일치된 의견에 의한 결정으로 헌법소원의 심판청구를 각하한다.

4. ***(4) 제68조제3항의 청구 사유에 해당하지 아니하는 것이 명백한 경우***

④ 지정재판부는 전원의 일치된 의견으로 제3항의 각하결정을 하지 아니하는 경우에는 결정으로 헌법소원을 재판부의 심판에 회부하여야 한다. 헌법소원심판의 청구 후 30일이 지날 때까지 각하결정이 없는 때에는 심판에 회부하는 결정(이하 “심판회부결정”이라 한다)이 있는 것으로 본다.

제75조(인용결정) ④ 제3항의 경우 침해의 원인이 된 공권력의 행사가 법원의 재판인 때에는 헌법재판소는 ***(6) 해당 재판을 취소한다.*** 이 경우 법원은 헌법재판소의 결정 취지에 따라 다시 재판하여야 한다.

---

7) 헌법재판소법, 법률 제21452호, 2026. 3. 12. 일부개정·시행, 제68조 제3항, 제69조 제1항 단서, 제71조의2, 제72조 제3항·제4항, 제75조 제4항. 이 표는 대상·청구사

이 조문구조의 핵심은 여섯 갈래다. 첫째, 대상은 확정된 재판이다. 둘째, 청구사유는 세 가지 유형으로 제한된다. 셋째, 청구기간은 확정일부터 30일이다. 넷째, 지정재판부가 청구기간, 보충성, 대리인 선임, 청구사유 명백성 등을 먼저 심사한다. 다섯째, 재판소원 제기만으로 자동정지효가 생기지는 않고, 별도의 가처분이 있을 때에만 그 범위에서 효력 또는 집행작용이 잠정 제한된다. 여섯째, 인용결정이 내려지면 헌법재판소가 해당 재판을 취소하고 법원이 다시 재판한다. 아래에서는 이 여섯 요소를 차례로 본다.

(1) 대상은 '확정된 재판'이다.

이 문언은 재판소원이 상소와 다르다는 점을 분명히 한다. 상소는 재판이 확정되기 전에 그 취소 또는 변경을 구하는 통상적 불복절차다. 반면 재판소원은 이미 확정된 재판을 헌법소송절차에서 문제 삼는 절차다. 따라서 재판소원이 제기되었다고 해서 대상재판이 미확정판결로 되돌아가지는 않는다. 재판소원을 사실상 4심으로 만들 수 있다는 우려는, 바로 이 지점에서 처음 통제된다.

(2) 청구사유는 세 가지로 제한된다.

첫째, 법원의 재판이 헌법재판소의 결정에 반하는 취지로 재판함으로써 기본권을 침해한 경우이다. 둘째, 법원의 재판이 헌법과 법률에서 정한 적법한 절차를 거치지 아니함으로써 기본권을 침해한 경우이다. 셋째, 법원의 재판이 헌법과 법률을 위반함으로써 기본권을 침해한 것이 명백한 경우이다. 이 세 사유는 재판소원을 일반적인 패소불복절차로 만들지 않기 위한 제한 장치이다. 특히 제1호는 헌법재판소 결정의 기속력과 법원 확정판결의 기판력 등 구속효가 충돌하는 유형을 정면으로 다룬다는 점에서 본고의 중심 대상이 된다.

---

유·청구기간·가처분·사전심사·인용효를 해당 조문 순서가 아니라 효력론상 문제되는 기능 순서로 재배열한 것이다. 입법자료도 대안의 주요내용에서 확정된 재판, 세 가지 청구사유, 확정일부터 30일의 청구기간, 재판서 및 확정증명원 첨부, 가처분, 지정재판부 각하, 재판취소와 법원의 다시 재판 구조를 함께 제시한다. 국회 법제사법위원장, "헌법재판소법 일부개정법률안(대안)", 의안번호 2216845, 2026. 2., 3-4면 참조.

(3) 청구기간은 확정일부터 30일로 제한된다.

이는 단순한 접수기간이 아니다. 제68조 제1항의 일반 권리구제형 헌법소원은 그 사유가 있음을 안 날부터 90일, 그 사유가 있는 날부터 1년 이내에 청구할 수 있다. 그에 비해 법원의 재판에 대한 헌법소원심판은 확정일부터 30일 이내에 청구해야 한다. 이 차이는 재판소원이 헌법소원의 한 유형이면서도 그 대상이 이미 확정된 재판이라는 점에서 나온다. 확정판결이 재판소원 때문에 무기한 불안정한 상태에 놓이면 종국성과 법적 안정성이 크게 약화된다. 그래서 30일 청구기간은 재판소원의 실효성과 확정판결의 안정성을 시간적으로 조정하는 문턱이다. 다만 30일 이내에 청구했다는 사정만으로 유동적 확정이 바로 발생하는 것은 아니다. 적법한 재판소원과 최소한의 심사가능성이 함께 인정되어야 한다.[8)]

(4) 사전심사 구조는 이 점을 더 선명하게 한다.

지정재판부는 청구기간 도과, 보충성 흠결, 대리인 선임 흠결, 제68조 제3항 청구사유의 명백한 부존재 등 일정한 경우 헌법소원심판청구를 각하한다. 반대로 지정재판부가 전원 일치로 각하결정을 하지 않으면 사건은 재판부 심판에 회부되고, 청구 후 30일이 지날 때까지 각하결정이 없으면 심판회부결정이 있는 것으로 본다.[9)] 이 구조는 재판소원 사건이 곧바로 본안심사로 넘어가는 것이 아니라, 먼저 적법성과 최소한의 심사가능성 문턱을 통과해야 함을 뜻한다. 따라서 사전심사는 사건관리절차에 머물지 않고 재판소원이 확정판결의 효력상태에 영향을 미칠 수 있는지 가르는 절차적 장치로서 기능한다.[10)]

---

8) 헌법재판소법 제69조 제1항 본문 및 단서. 제68조 제1항에 따른 헌법소원은 사유가 있음을 안 날부터 90일, 사유가 있는 날부터 1년 이내에 청구하여야 하나, 법원의 재판에 대한 헌법소원심판은 그 확정일부터 30일 이내에 청구하여야 한다. 헌법재판소, “권리구제형 헌법소원심판 청구 안내”, 2026, 1-2면도 일반 권리구제형 헌법소원의 90일·1년 기간과 재판소원의 30일 기간, 사전심사 요건을 함께 안내한다. 30일 기간은 재판소원의 청구기간일 뿐이고, 유동적 확정의 발생 여부는 제68조 제3항 청구사유와 제72조 제3항·제4항의 사전심사 구조를 함께 보아 판단하여야 한다.

9) 사전심사와 심판회부결정 구조는 헌법재판소법 제72조 제3항·제4항에서 확인된다. 특히 같은 조 제3항 제4호는 제68조 제3항의 청구 사유에 해당하지 아니하는 것이 명백한 경우 지정재판부가 각하할 수 있도록 한다.

10) 시행 초기 통계에서도 지정재판부 단계의 각하가 적지 않았다는 점이 나타난다. 그러나 그 통계는 사전심사의 문턱이 실제로 작동한다는 뜻이지, 유동적 확정이 실무

(5) 가처분 규정은 유동적 확정을 설명하는 핵심 장치로 기능한다. 개정법은 헌법재판소가 직권 또는 청구인의 신청에 따라 종국결정 선고 전까지 심판대상이 된 공권력의 효력을 정지할 수 있도록 한다.[11] 그러나 재판소원 제기 자체가 확정판결의 효력이나 집행력을 자동으로 정지시키는 것은 아니다. 자동정지효가 인정된다면 재판소원은 사실상 상소와 비슷한 효과를 갖기 때문이다. 따라서 원칙적으로 확정판결의 효력과 집행력은 유지되고, 예외적으로 헌법재판소의 가처분이 있는 경우에만 그 범위에서 효력 또는 집행작용이 잠정적으로 제한된다.

(6) 인용결정의 효과는 가처분보다 더 직접적이다. 침해의 원인이 된 공권력 행사가 법원의 재판인 경우, 헌법재판소는 해당 재판을 취소하고 법원은 헌법재판소 결정 취지에 따라 다시 재판하여야 하며 이는 재판소원 인용의 직접효가 해당 재판의 취소라는 뜻이다. 동시에 헌법재판소가 사건의 실체적 결론을 전면적으로 대체하는 것은 아니라는 뜻이기도 하다. 헌법재판소는 헌법적 하자를 이유로 해당 재판을 취소하고, 구체적 사건의 재판기능은 다시 법원에 맡긴다.[12]

---

상 공집합이라는 뜻은 아니다. 2026년 6월 9일 기준 누적 8건이 전원재판부에 회부되었다는 이후 통계는, 심사가능성이 드문 사건을 선별하되 실제로 효력조정 국면을 열 수 있는 문턱임을 보여준다. 시행 초기 지정재판부 단계에서 각하가 적지 않았다는 경험적 배경으로는 "재판소원 시행 한 달, 395건 중 194건 각하…'청구 사유 미비'", 『경향신문』, 2026. 4. 13.; 이후 누적 회부 사건이 나타났다는 보도로는 "헌재, 재판소원 2건 전원재판부 추가 회부… 총 8건 심리", 『법률신문』, 2026. 6. 9. 위 자료들은 시행 초기 사전심사 운용의 배경자료로만 사용한다. 법원 사건 규모에 관한 공식 통계로는 법원행정처, "2025 사법연감 발간", 보도자료, 2025. 9. 23., 8-10면; 법원행정처, 『2025 사법연감』, 2025, 866면, 904면. 위 사법연감 표에서 2015-2024년 평균 제1심 민사본안 접수건수는 합의 39,952건·단독 857,759건이고, 제1심 형사공판 접수인원수는 합의 20,652명·단독 226,225명이다. 2024년 법원 접수 소송사건은 6,915,400건이고, 민사본안사건은 879,799건, 형사본안사건은 347,292건이다. 확정판결 수 자체의 직접 통계는 아니지만, 제1심 민사본안·형사공판 접수 규모만 보아도 최근 10년 평균이 각각 897,711건, 246,877명에 이른다. 이런 규모에서는 모든 확정재판을 30일 동안 곧바로 유동적 확정으로 보는 설명은 지나치게 넓다.

11) 잠정조치로서 가처분제도는 그 본안종속성이나 헌법재판의 한계를 넘어서는 규율로 파악하여, 헌법재판 가처분이 본안선취 및 권력분립 문제를 낳을 수 있으므로 신중해야 한다는 지적으로는 이준상, "헌법재판에서의 가처분 - 최근 입법논의와 관련하여 -", 『사법』 제1권 제13호, 사법발전재단, 2010, 147-150면, 154-155면 참조.

정리하자면, 개정 헌법재판소법의 조문구조는 다음 세 원칙으로 압축된다.

<표 3> 개정 조문구조의 세 원칙

| |
|---|
| 첫째, 확정판결의 원칙적 효력은 유지된다.<br>둘째, 재판소원 제기만으로 자동정지효는 발생하지 않는다.<br>셋째, 적법한 재판소원과 심사가능성이 인정되고, 가처분 또는 인용결정이 내려지는 경우에 한하여 확정판결의 효력작용은 제한적으로 조건화된다. |

## 2. 판결례적 전사(前史)

재판소원은 2026년에 갑자기 만들어진 제도가 아니다. 종전 헌법재판소법은 법원의 재판을 헌법소원의 대상에서 제외했고, 그래서 재판소원금지 원칙이 오랫동안 유지되었다. 그러나 이 원칙은 처음부터 논쟁의 대상이 되었는데, 헌법소원이 국가작용이 기본권을 침해했는지 심사하는 제도임에도 국가작용인 '법원의 재판'이 제외되었기 때문이다. 요컨대 법원의 재판을 전부 제외하는 것이 헌법소원의 취지와 맞는지에 관하여 계속 비판이 제기된 것이다. 이에 대해 헌법재판소는 재판소원금지 원칙을 부정하진 않은 대신, 매우 좁은 예외를 만들었다. 그 출발점이 헌재 1997. 12. 24. 96헌마172·173 병합, 이른바 '1997년 결정'이다. 이 결정에서 헌법재판소는 법원의 재판을 원칙적으로 헌법소원 대상에서 제외한다고 보았다. 다만 헌법재판소가 위헌으로 결정한 법령을 법원이 그대로 적용하여 국민의 기본권을 침해한 재판은 예외적으로 헌법소원의 대상이 될 수 있다고 하여, 법원 재판 일반을 다시 심사하겠다는 것이 아닌 헌법재판소 위헌결정의 효력을 지키기 위한 최소한의 예외를 인정하였다.[13]

---

12) 인용결정으로 법원의 재판이 취소되고 법원이 헌법재판소 결정 취지에 따라 다시 재판하여야 한다는 점은 헌법재판소법 제75조 제4항 참조.

13) 헌재 1997. 12. 24. 선고 96헌마172·173 결정. 1997년 결정이 위헌결정된 법령을 적용한 법원 재판을 예외적 헌법소원 대상으로 보았고 2022년 결정과 이어진다는 분석으로는 박경철, "법률에 대한 위헌결정의 효력과 헌법소원의 대상이 되는 법원 재판 — 헌재 2022. 6. 30. 선고, 2014헌마760, 2014헌마763 결정에 대한 헌법적 검토",『공법연구』제52집 제2호, 한국공법학회, 2023, 458-466면 참조.

다음 쟁점은 한정위헌결정의 기속력이었다. 한정위헌결정은 법률조항 자체를 전부 없애는 결정이 아니라, 그 법률조항의 특정한 해석이나 적용범위를 헌법에 맞지 않는 것으로 배제하는 결정이다. 이때 법원이 그 결정에 구속되는지가 문제였다. 대법원은 법률해석권이 법원의 본질적 권한이라고 보았고, 헌법재판소와 이를 지지하는 견해는 위헌적인 법률의 의미를 배제하는 결정도 법률에 대한 위헌결정이므로 법원을 기속한다고 보았다.[14] 한쪽에는 구체적 사건을 끝내는 법원의 재판권과 확정판결의 안정성이 있고 다른 쪽에는 헌법재판소 결정의 기속력과 헌법의 최고규범성이 있었다는 점에서, 이 논쟁은 단순한 기관 간 위상을 다툰 것으로만 볼 순 없다. 이에 따라 논점 역시 두 갈래로 나뉘었다. 하나는, 헌법재판소가 위헌법률심판절차에서 법원의 법률해석이 맞는지를 심사해서는 안 된다는 견해였고 다른 하나는 법률은 해석을 통해서만 실제 규범으로 작동하는 이상, 위헌적인 해석부분을 배제하는 한정위헌결정도 국가기관을 기속한다는 견해였다.[15]

헌재 2022. 6. 30. 2014헌마760·763 병합, 이른바 '2022년 결정'은 이 흐름을 한 단계 더 밀고 나갔다. 헌법재판소는 법률에 대한 위헌결정의 기속력에 반하는 재판은 예외적으로 헌법소원의 대상이 될 수 있다고 보아, 한정위헌결정의 기속력

14) 한정위헌결정의 법원에 대한 기속력 논쟁 전반에 관하여는 이덕연, "限定違憲決定의 法院에 대한 羈束力 問題", 『공법학연구』 제12권 제3호, 한국비교공법학회, 2011, 183-190면; 조소영, "현행 헌법상 헌법재판제도에 대한 비판적 고찰 — 한정위헌결정에 관한 논쟁을 중심으로", 『강원법학』 제40권, 강원대학교 비교법학연구소, 2013, 40-44면; 송승현, "한정위헌결정의 기속력의 인정여부에 대한 대법원과 헌법재판소의 위험한 힘겨루기", 『법학논총』 제23권 제1호, 조선대학교 법학연구원, 2016, 179-184면 참조.

15) 요컨대 이 대립은 재판소원 문제의 뒤에 두 효력체계가 있다는 점을 보여준다. 하나는 확정판결의 기판력 등 구속효이고, 다른 하나는 헌법재판소 결정의 기속력이다. 위헌법률심판절차에서 법원의 법률해석 당부를 심사할 수 있는지에 대한 비판론으로는 김시철, "위헌법률심판절차에서 사법작용의 당부를 심사할 수 있는지(上)" 및 "위헌법률심판절차에서 사법작용의 당부를 심사할 수 있는지(下)", 『사법』 제21호·제22호, 사법발전재단, 2012, 특히 (上) 179면의 각주23'사법적 유권해석' 및 (下) 312-314면 참조. 한정위헌결정의 기속력을 인정하는 입장과 대법원 대응 비판에 관하여는 남복현, "법률해석과 관련한 헌법재판소와 대법원의 갈등, 그 원인과 해법 — 대법 2013. 3. 28. 선고 2012재두299 판결을 중심으로", 『법학논고』 제45집, 경북대학교 법학연구원, 2014, 118-121 및 124면 참조.

을 부인하여 재심청구를 기각한 법원 재판을 취소하였다. 앞서 1997년 결정이 '위헌결정된 법령을 적용한 재판'을 문제 삼았다면, 2022년 결정은 '위헌결정의 기속력에 반하는 재판'을 문제 삼은 것이다. 다시 말해 예외적 재판취소 법리가 한 단계 확장된 것이다.[16] 그러나 '2022년 결정'도 재판소원을 전면 허용한 것은 아니었다. 헌법재판소는 위헌결정 이후의 재심기각결정은 취소하면서도, 위헌결정 전에 이미 확정된 원 유죄판결 자체는 헌법소원의 대상이 아니라고 보았기에[17] 이를 확정판결 일반을 헌법재판소가 다시 심사할 수 있다는 선언으로 보는 것은 어렵다. 다만 헌법재판소 결정의 기속력과 정면으로 충돌하는 특정한 법원 재판을 예외적으로 통제한 결정으로 봄은 상당할 것이다.[18]

2026년 개정 헌법재판소법은 이 판례법적 흐름을 조문으로 바꾸었다. 개정법은 법원의 재판에 대한 헌법소원을 계속 제한하면서도, 일정한 사유가 있는 확정재판에는 재판소원을 허용한다. 특히 제68조 제3항 제1호는 "헌법재판소의 결정에 반하는 취지의 재판"을 청구사유로 명시하였다. 이 문언은 1997년 결정과 2022년 결정에서 형성된 기속력 위반형 재판취소 법리를 법률상 유형으로 받아들인 것이다.

## 3. 효력론적 긴장의 발생

앞의 두 절에서 보았듯이, 2026년 재판소원 제도는 두 방향을 동시에 가진다. 한편으로 개정법은 재판소원의 대상을 '확정된 재판'으로 한정하고, 30일 청구기간과 사전심사 구조를 두어 남용 가능성을 통제한다. 다른 한편으로 개정법은 가처분, 해당 재판취소, 법원의 재재판 구조를 명문으로 두어 일정한 경우 확정판결의 효력작용이 바뀔 수 있음을 인정한다. 그러나 문제는, 이때의 확정판결을 여전히 확정판결으로 '볼 수' 있는지, 아니면 헌법재판소 절차에 들어온 순간부터 다른 효력상태에 놓이는지에 놓여있다. 이러한 긴장상태를 표로 정리하면 다음과 같다.

16) 헌재 2022. 6. 30. 선고 2014헌마760·763 결정

17) 2022년 결정이 재심기각결정은 취소하면서도 위헌결정 이전에 확정된 원 유죄판결의 대상적격은 부정하였다는 점에 관하여는 박경철, 앞의 글(주 13), 467-472면 참조.

18) 본문은 두 결정이 재판소원금지 원칙을 전면 폐기한 것이 아니라 헌법재판소 결정의 실효성을 확보하기 위한 예외 법리를 형성했다는 점에 주목한다.

<표 4> 재판소원이 제기된 확정판결의 효력론적 긴장

| |
|---|
| ($a$) 대상재판은 확정판결이다. |
| ($b$) 따라서 그 재판은 원칙적으로 형식적 확정력, 기판력, 집행력을 가진다. |
| └($b''$) 확정판결의 기판력은 분쟁의 종국적 해결을 위하여 인정되는 효력이고, 당사자와 법원은 일정한 범위에서 그 판단에 구속된다.[19] |
| ($c$) 그러나 재판소원 절차에서 헌법재판소가 가처분을 발령하면 그 효력 또는 집행작용은 잠정적으로 제한될 수 있고, 본안에서 인용결정이 내려지면 해당 재판은 취소되며 법원의 재재판으로 이어진다. |

이 구조는 기존의 이분법으로는 설명되지 않는다. 다시 말해 ⓐ재판소원이 제기되었다는 이유만으로 대상판결이 미확정판결로 돌아가는 것은 아니지만, ⓑ 적법한 재판소원이 제기되고 심사가능성이 인정되면, 그 확정판결의 효력변동 가능성은 더 이상 일반 확정판결에 내재하는 추상적 재심가능성에 머물지 않는다. 요컨대 그 가능성은 헌법재판소 절차 안에서 현실적인 심판대상으로 드러나는 이상, 재판소원이 제기된 확정판결을 통상적 확정판결과 완전히 같다고도 보기 어렵다.

만약 재판소원을 제기하였다는 사정만으로 기판력이나 집행력이 소멸한다고 보면, 재판소원은 사실상 또 하나의 상소가 된다. 반대로 재판소원이 제기된 확정판결을 통상적 확정판결과 완전히 같게 취급하면, 개정 헌법재판소법이 둔 가처분, 재판취소, 재재판 구조를 설명할 수 없다. 따라서 필요한 것은 확정판결의 효력을 유지하면서도 헌법재판소 결정이 미칠 수 있는 효과를 단계적으로 설명하는 관점이다. 이를 본고는 '효력조정론'이라고 부른다.[20] 이하 Ⅲ장에서는 이러한

19) 기판력의 개념과 범위에 관하여는 강현중, 앞의 글(주 1), 100-102면; 김성혁, "기판력의 객관적 범위와 작용국면으로서의 모순관계 - 소유권이전등기청구소송과 말소등기청구소송을 중심으로 -", 『법학연구』 통권 제67집, 전북대학교 법학연구소, 2021, 201-202면; 김상영, "기판력의 작용과 범위의 관계", 『법학연구』 제57권 제3호, 부산대학교 법학연구소, 2016, 318면; 석현수, "기판력 작용의 요건", 『한양법학』 제26권 제3집, 한양법학회, 2015, 133면 및 150면 참조.

20) 효력조정론은 두 전제에서 출발한다. 첫째, 확정판결의 효력은 하나의 덩어리가 아니다. 형식적 확정력, 기판력, 집행력, 제3자적 효력, 법률요건적 효력 등 서로 다른 층위로 나누어 보아야 한다. 둘째, 헌법재판소 결정의 기속력은 확정판결의 기판력

효력조정론의 전제가 되는 확정판결의 효력구조와 헌법재판소 결정의 기속력을 검토한다. 이어 Ⅳ장에서는 그 논의를 바탕으로 유동적 확정의 정의, 발생 요건, 효력별 작동 방식과 종료, 그리고 재심 등 인접 제도와의 구별을 정식화한다.

## Ⅲ. 확정판결의 효력과 헌법재판소 결정의 기속력

### 1. 확정판결의 다층적 효력

#### (1) 효력의 층위

확정판결의 효력은 하나로만 설명될 수 없는바, 이는 통상적인 불복절차로 더 이상 다툴 수 없게 하는 형식적 확정력과 판결의 판단이 일정한 범위에서 당사자와 후소 법원을 구속하는 기판력이 있다. 일정한 경우에는 강제집행의 근거가 되는 집행력도 문제되며, 형성판결의 형성력, 판결의 법률요건적 효력, 제3자적 효력, 반사효 등 기판력과 다른 방식으로 법률관계에 영향을 미치는 효력도 논의된다.[21] 이처럼 확정판결의 효력은 단층 구조가 아니라 여러 층위의 구조를 가진다.

재판소원 논의에서 이러한 구분은 중요한데, 재판소원이 제기되었다고 해서 확정판결의 모든 효력이 한꺼번에 사라지는 것은 아니기 때문이다. 형식적 확정력은 그대로 유지되고, 기판력도 원칙적으로 유지된다. 나아가 재판소원 제기 자체

---

과 같은 성질의 효력이 아니다. 그것은 법원과 그 밖의 국가기관을 구속하는 규범통제 효과이고, 그 범위는 결정주문과 그 주문의 의미를 형성하는 핵심적 이유를 중심으로 정해져야 한다. 따라서 재판소원이 제기된 확정판결을 하나의 덩어리로 보지 말고, 어떤 효력은 유지되고 어떤 효력작용은 제한될 수 있는지 나누어 보아야 한다. 이하에서 '정착-유동-해소'로 나누는 것은 확정판결의 효력을 기존 기판력론의 반복이 아니라 재판소원 절차와 결합한 시간적 상태로 설명하기 위한 분석틀이다.

21) 이에 대해 비교법적 사료 중 독일에서의 Schwab과 Koussoulis에 의하여 판결의 제3자적 효력이 집중적으로 검토되어 온 것에 주목하여 기판력, 집행력, 형성력, 법률요건적 효력 등으로 논리전개하는 선행연구가 존재한다. 특히 판결의 제3자적 효력을 다섯 가지 유형으로 정리한 것으로서 남동현, "판결의 제3자적 효력의 본질과 그밖의 판결의 효력에 관한 검토", 『비교사법』 제15권 제2호, 한국사법학회, 2008, 345면 및 349-350면 참조.

에는 자동정지효가 없으므로 집행력도 원칙적으로 유지된다. 다만 적법한 재판소원이 제기되고 심사가능성이 인정된 뒤, 헌법재판소가 가처분을 발령하거나 본안에서 인용결정을 하면 일부 효력작용은 제한되거나 재구성될 수 있다. 따라서 재판소원이 제기된 확정판결의 효력상태는 효력별로 나누어 보아야 한다.

### (2) 형식적 확정력과 기판력

형식적 확정력은 통상적인 불복절차로 그 재판을 더 이상 다툴 수 없게 되는 효력이다. 상소는 재판이 확정되기 전에 상급법원에 취소 또는 변경을 구하는 절차이다. 그래서 상소가 제기되면 그 재판은 아직 확정되지 않는다.[22] 반면 재판소원은 이미 확정된 재판을 대상으로 하는 별도의 헌법소송 절차로서 청구가 제기되어도 대상판결이 미확정판결로 되돌아가지는 않는다. 요컨대 재판소원은 형식적 확정력을 없애는 절차가 아니라, 형식적으로 확정된 재판에 남아 있는 헌법적 하자를 예외적으로 심사하는 절차다.

확정판결의 핵심적 효력인 기판력은 확정된 종국판결이 당사자의 청구에 관하여 내린 판단을 후속 절차에서 다시 다투지 못하게 하는 힘이기에[23] 당사자는 후소에서 그 판단에 반하는 주장을 할 수 없고, 다른 법원도 그 판단에 저촉되는 판단을 할 수 없다.[24][25]

---

22) 강현중, 앞의 글(주 3), 72-73면.

23) 이하에서 말하는 기판력은 주로 민사·행정 판결의 소송상 구속효를 중심으로 한다. 형사판결은 형식적 확정력, 일사부재리적 효력, 형 집행의 근거 등 별도의 효력구조를 가지므로, 본고의 구체적 논증은 민사·행정 확정판결의 기판력 작용평면을 중심으로 전개한다.

24) 이때 기판력의 객관적 범위와 작용국면을 구별해야 하는바, 이는 민사소송법 제216조 제1항은 확정판결이 "주문에 포함된 것"에 한하여 기판력을 가진다고 정하고 있는 사실에 기인한다. 이 말은 판결주문에 적힌 모든 표현이나 판결이유의 모든 판단에 기판력이 생긴다는 뜻이 아니며, 주문에서 판단된 소송물에 관한 결론을 중심으로 기판력이 발생한다는 뜻이다. 이하 강현중, 앞의 글(주 1), 134-140면; 석현수, 앞의 글(주 19), 149-153면.

25) 나아가 기판력은 전소와 후소의 소송물이 같은 경우뿐 아니라, 전소의 판단이 후소의 선결문제가 되는 경우 또는 후소의 소송물이 전소에서 확정된 법률관계와 모순되는 경우에도 문제될 수 있다. 따라서 "기판력이 어디까지 미치는가"와 "그 기판력

다만 형사 확정판결도 유동적 확정 논의에서 제외되는 것은 아니다. 형사판결에서는 기판력이라는 말보다 형식적 확정력, 일사부재리적 효력, 형 집행의 근거성이 중심이 된다. 적법한 재판소원과 심사가능성이 있어도 유죄판결의 확정이나 형 집행이 당연히 소멸·정지되는 것은 아니다. 그러나 가처분은 형 집행 등 효력작용을 잠정 제한할 수 있고, 인용결정은 헌법재판소법 제75조 제4항에 따라 해당 재판의 취소와 다시 재판으로 이어진다. 이는 형벌법규 위헌결정 후 재심청구권을 정한 헌법재판소법 제47조 제4항과 구별된다. 따라서 형사판결에서도 유동적 확정은 일사부재리나 형 집행 근거성을 부정하지 않고, 헌법소원절차 위에 드러난 제한적 효력조정 가능성을 설명한다.

### (3) 집행가능성과 '집행의 위험'

확정판결은 일정한 요건 아래 강제집행의 집행권원이 될 수 있다. 그러나 집행력은 기판력과 효력이 같지는 아니한바, 기판력이 후소에서 당사자와 법원을 구속하는 소송상 효력이라면 집행력은 판결에 표시된 급부를 국가의 강제력으로 실현할 수 있게 하는 효력이라는 차이에 연유한다. 개정 헌법재판소법상 재판소원 제기 자체에 자동정지효가 없는 한, 유동적 확정상태에서도 집행력은 원칙적으로 유지된다. 그러나 헌법재판소가 가처분을 발령하면, 그 범위에서 판결의 효력 또는 집행작용은 잠정적으로 제한될 수 있다.

이때 '집행 가능성'과 '집행의 위험 구조'는 구별되어야 한다. 재판소원이 제기된 확정판결에 기초한 집행은 법률상 원칙적으로 가능하지만, 적법한 재판소원과 심사가능성이 인정되는 경우 그 집행은 헌법재판소의 가처분이나 인용 결정에 따라 효력변동이 생길 수 있다는 위험을 내포한다. 이 의미에서 유동적 확정은 집행력을 부정하는 개념이 아니라, 집행력의 근거가 되는 확정판결이 효력상 어떤 상태에 놓여 있는지를 표시하는 개념이다. 가처분 및 가집행선고부 판결과의 사고형식적 비교는 Ⅳ장에서 별도로 검토한다.

---

이 후소에서 어떻게 작용하는가"는 구별해야 한다. 판결주문의 형식과 기판력의 객관적 범위에 관하여는 김일룡, "판결주문의 형식과 기판력의 객관적 범위의 관계", 『동아법학』 제53호, 동아대학교 법학연구소, 2011, 344-350면; 기판력의 작용국면에 관하여 소유권이전등기청구권의 부존재에 대해서도 발생하는지 여부를 검토한 사례로서 김성혁, 앞의 글(주 19), 211-216면 참조.

#### (4) 제3자와 후속 법률관계

민사소송법 제218조 제1항은 일정한 경우 변론종결 후 승계인에게도 확정판결의 효력이 미친다고 정하고 있어, 확정판결의 효력은 당사자 사이에만 머무르지 않는다. 이러한 주관적 확장은 확정판결의 권위와 법적 안정성을 보여줄 수 있지만, 이러한 목적을 유지·존속하기 위해서라도 이 문제에 대해 재판소원에선 조심스럽게 다루어야 한다. 해당 재판이 취소된다고 하여 그 재판을 기초로 이미 형성된 모든 제3자 관계나 후속 법률관계가 당연히 일률적으로 소급 무효화된다고 볼 수는 없다. 기판력, 집행력, 제3자적 효력, 법률요건적 효력은 서로 다른 층위에서 작동하기 때문이다.

#### (5) 소결

확정판결의 효력은 다층적인 이상, 재판소원이 제기된 확정판결의 효력상태를 하나의 명제만으로 일률적으로 설명할 순 없다. 재판소원이 제기되었다고 해서 확정판결의 모든 효력이 한꺼번에 소멸하는 것은 아니다. 그렇다고 형식적 확정력, 기판력, 집행력이 원칙적으로 유지된다고 하여 재판소원이 제기된 확정판결을 통상적 확정판결과 완전히 같게 볼 수도 없다. 그러나 적법한 재판소원이 제기되고 심사가능성이 인정되면, 그 효력작용은 헌법재판소법상 가처분, 재판취소, 재재판 구조에 따라 조건부로 조정될 수 있다. 요컨대 유동적 확정은 바로 이러한 다층적 효력구조를 전제로, 재판소원 절차와 결부된 확정판결의 특유한 효력상태를 설명하기 위한 개념이다.

### 2. 헌법재판소 결정의 효력

헌법재판소 결정의 효력은 그 결정의 종류와 주문 형식에 따라 확정력·기속력·법규적 효력·재심사유·공권력 행사 취소 또는 위헌확인 효과가 서로 다르게 작동한다. 예컨대 법률에 대한 위헌결정은 헌법재판소법 제47조 제1항에 따라 법원과 국가기관 및 지방자치단체를 기속하고, 같은 조 제2항 이하에 따라 법률조항의 효력상실과 형벌법규의 소급효, 재심청구 가능성을 낳을 수 있다. 헌법소원 인용

결정도 제75조 제1항에 따라 국가기관과 지방자치단체를 기속하며, 필요한 경우 침해의 원인이 된 공권력 행사를 취소하거나 그 불행사가 위헌임을 확인한다.

이때 재판소원에서 특히 문제되는 것은 기속력으로, 이는 헌법재판소 결정이 법원과 국가기관 및 지방자치단체의 후속 행위를 구속하여 그 결정의 취지와 양립하기 어려운 행위를 하지 못하게 하는 효력을 칭한다.[26] 헌법재판의 실효성을 확보하기 위해 국가기관의 장래 행위를 구속하는 효력으로서 기속력과 구분되는 개념으로, 기판력은 구체적 소송에서 당사자 사이의 소송물 판단을 확정하고 후소 법원과 당사자의 모순된 주장을 차단하는 효력이다. 두 효력은 모두 구속력을 가지지만, 근거·상대방·범위·작용국면이 다르다.

그렇다면 기속력이 어디까지 미치는지 문제되는바, 본고는 이를 결정 이유 전체로 넓히지 않고, 주문의 문언만으로 좁히지도 않는다. 결정주문이 원칙이지만, 그 주문의 뜻을 확정하는 데도 필요한 이유는 주문해석의 범위 안에서 함께 읽어야 하기 때문이다. 이는 결정 이유 자체에 별도의 기속력을 부여한다는 뜻이 아니라, 주문을 가능하게 한 핵심 이유를 빼고는 주문의 의미를 정확히 알 수 없는 경우가 있다는 것을 뜻한다.[27]

---

26) 그러나 허완중은 이에 대해 헌법재판소결정의 기속력은 자주 그 실효성을 의심받는다고 지적하며 실효성 보장을 위한 논의를 전개하였다. 이하 허완중, "헌법재판소결정의 기속력",『헌법판례연구』제13권, 한국헌법판례연구학회, 2012, 318면 본문 및 각주 4-9 인용, "입법자는 이따금 그의 진정입법부작위가 위헌으로 결정되었어도 법률을 제정하지 않은 바 있다. 드물지 않게 헌법재판소가 헌법에 합치하지 않는다고 선언한 법률을 개선하지도 않았다. 근래에는 입법자가 위헌으로 결정된 법률과 같은 내용의 법률을 다시 제정한 때도 있었다. 대법원도 헌법재판소의 한정위헌결정이 기속력을 가질 수 없다는 판결을 내렸을 뿐 아니라 두 개의 헌법불합치결정과 다른 판결을 내린 적도 있다. 또한, 행정부도 때때로 헌법재판소결정을 무시한다. 예를 들어 검사의 불기소처분이 위헌으로 결정되고 나서 검사가 해당 사건에 대해서 다시 불기소처분을 내렸다가 재차 그 불기소처분을 취소당한 때가 있었다. 이때에 다른 국가기관은 기속력의 범위와 한계를 다툼으로써 헌법재판소결정의 구속에서 벗어나려고 한다."

27) 한 선행연구는 독일연방헌법재판소의 결정이유 기속력 논의과정에서 '주된 이유 없이 주문은 논증될 수 없기 때문에 주된 이유가 주문을 포용하고 뒷받침한다는 것은 그것 없이는 판결은 어쩌면 다른 결과를 가져올지도 모른다는 의미에서 매우 중요한 것'이라 언급하였다. 다만 동저는 헌법재판소의 정형결정에는 별 문제가 없을지도 모르나 변형결정의 경우 문제가 제기될 수 있음을 지적하였다. 이하 이기철,

이 기준은 헌법재판소법 제68조 제3항 제1호에서 중요하다. 제1호는 법원 재판이 헌법재판소 결정에 반하는 취지로 재판하여 기본권을 침해한 경우를 재판소원 사유로 정한다. 여기서 반하는 취지를 판단하려면 먼저 선행 헌법재판소 결정이 무엇을 금지하거나 배제했는지 확인해야 한다. 한정위헌결정이나 헌법불합치결정처럼 주문과 이유가 긴밀하게 얽힌 결정에서는, 주문의 뜻을 밝히는 핵심 이유를 함께 보아야 한다. 다만 그 범위는 좁고 엄격해야 한다. 결정 이유 중 방론, 일반론, 부수적 논거까지 모두 법원을 직접 구속한다고 보면, 제68조 제3항 제1호는 법원 재판의 일반적 법률해석을 통제하는 절차로 확대될 수 있기 때문이다. 이 경우 재판소원은 사실상 4심으로 변질될 수 있으므로, 제1호에서 정의한 '결정에 반하는 취지'는 선행 결정의 주문과 그 주문의 의미를 형성하는 핵심 이유에 실질적으로 어긋나는 경우로 한정해야 한다.[28]

'2022년 결정'에서 헌법재판소는 한정위헌결정의 기속력을 부인하고 재심청구를 기각한 법원 재판을 헌법소원의 대상이 되는 재판으로 보아 취소하였다. 그러나 한정위헌결정 전에 이미 확정된 원 유죄판결 자체에 대해서는 대상적격을 인정하지 않았다. 즉, 그 결정은 어디까지나 기속력 위반 재판을 통제한 것이지, 확정판결 일반을 다시 심사한 것이 아니다. 이 점에서 헌법재판소 결정의 기속력은 재판소원에서 두 기능을 가진다. 하나는 헌법재판의 실효성을 지키는 기능이고, 다른 하나는 그 효력이 무제한으로 넓어지지 않도록 범위를 특정해야 한다는 기능이다. 생각건대 결국 필요한 것은 기속력의 절대화도, 기판력의 절대화도 아닌 이상, 두 효력의 근거와 범위를 나누고 충돌하는 부분만 절차적으로 조정하는 설명이 필요하다. 이 지점에서 유동적 확정 개념이 요청된다.

## 3. 두 효력의 충돌과 효력조정론

앞서 보았듯 법원 확정판결의 기판력과 헌법재판소 결정의 기속력은 모두 구속

"헌법재판소결정은 주된 이유에도 기속력이 미치는가?", 『한양법학』 제13집, 한양법학회, 2002, 80-84면.

28) 한정위헌결정과 법원의 법률해석권 충돌에 관하여는 남복현, 앞의 글(주 15), 117-120면; 이동훈, "헌법재판에서 변형결정의 기속력", 『공법학연구』 제17권 제2호, 한국비교공법학회, 2016, 115-122면; 이덕연, 앞의 글(주 14), 186-187면; 조소영, 앞의 글(주 14), 40-42면; 송승현, 앞의 글(주 14), 182-187면 참조.

력을 가지지만, 묶는 대상과 이유가 다르기에 어느 정도의 긴장이 있음을 무시할 수 없다. 그러나 두 판단 사이에 긴장이 있다는 이유만으로 언제나 재판소원이 허용되는 것은 아니다. 법원이 헌법재판소 결정과 다른 법률해석을 했다는 주장만으로는 부족하고 패소자가 사실인정, 증거평가, 법률적용의 당부를 다시 다투려는 경우도 재판소원 사유가 아니다. 반대로 헌법재판소 결정의 기속력을 너무 넓게 보아도 문제가 생긴다. 결정이유의 일부 표현이나 방론까지 모두 법원을 직접 구속한다고 보면, 헌법재판소가 법원 재판의 일반적인 법률해석을 다시 심사하는 상급심처럼 기능할 수 있다.

본고가 제언하는 효력조정론은 기판력과 기속력 중 어느 하나를 없애려는 시도가 아니다. 확정판결은 원칙적으로 존중되고, 재판소원 제기만으로 형식적 확정력, 기판력, 집행력이 사라지지 않는다. 동시에 법원도 헌법재판소가 위헌으로 배제한 규범 의미를 다시 적용하여 기본권을 침해해서는 안 된다. 문제는 두 요청이 충돌하는 예외적 국면에서 어느 효력을, 어떤 절차와 범위 안에서 조정할 것인가이다. 본고는 그 기준을 다음 네 가지로 정리하고자 한다.

첫째, 충돌 대상이 구체적으로 특정되어야 한다. 선행 헌법재판소 결정의 주문, 그 주문의 의미를 이루는 핵심 이유, 대상 법원 재판의 규범전제가 실제로 부딪히는지 보아야 한다. 단순한 법률해석상 견해 차이나 결정이유 중 일반론과의 긴장만으로는 부족하다. 제68조 제3항 제1호의 반하는 취지는 선행 결정이 배제한 규범 의미를 법원이 다시 적용하거나, 선행 결정의 기속력을 실질적으로 부인한 경우를 중심으로 이해해야 한다.

둘째, 그 충돌이 기본권 침해로 이어져야 한다. 제68조 제3항 제1호는 헌법재판소 결정에 반하는 재판 자체만을 문제 삼지 않는다. 그러한 재판으로 기본권이 침해된 경우를 요구한다. 따라서 추상적인 기관 충돌만으로는 부족하다. 청구인의 기본권 침해로 연결될 때 비로소 재판소원 사유가 될 수 있다.

셋째, 충돌 가능성이 절차 위에 드러나야 한다. 일반 확정판결도 재심사유가 생기면 다시 다투어질 수 있다. 그러나 이는 별도의 재심사유와 재심청구를 기다리는 잠재적 가능성이다. 반면 적법한 재판소원이 제기되고 심사가능성이 인정되면, 효력변동 가능성은 헌법재판소 절차 안에서 현실화된다. 이 차이가 유동적 확정을 통상적 확정판결과 구별한다.

넷째, 효력변동은 효력별로 나누어 조정해야 한다. 재판소원 제기만으로 형식적

확정력, 기판력, 집행력이 모두 사라지는 것은 아니다. 가처분이 없으면 집행력도 원칙적으로 유지된다. 인용결정이 내려지면 해당 재판은 취소되고, 법원은 그 결정 취지에 따라 다시 재판한다. 그 뒤 제3자 관계나 후속 법률관계는 기판력, 집행력, 제3자적 효력, 반사효 등 각 효력의 성질에 따라 따로 조정되어야 한다.[29]

이 점에서 유동적 확정은 효력조정론을 짧게 표현하는 핵심 개념이다. 유동적 확정은 확정판결의 기판력을 부정하지 않는다. 형식적 확정력, 기판력, 원칙적 집행력은 유지된다. 다만 적법한 재판소원이 제기되고 심사가능성이 인정되면, 그 효력작용이 헌법재판소의 가처분 또는 인용결정에 따라 제한되거나 재구성될 수 있다. 그러므로 핵심 질문은 확정판결을 다시 열 수 있는가가 아니다. 더 정확한 질문은 확정판결의 어떤 효력이, 어떤 헌법소송 절차의 조건 아래, 어느 범위에서 조정될 수 있는가이다.

## Ⅳ. 유동적 확정의 정식화

### 1. 공법상 효력유지 구조와 유동적 무효의 착안

앞의 논의에서 보았듯, 재판소원이 제기된 확정판결은 단순히 미확정판결로 돌아가지 않는다. 그러나 적법한 재판소원이 제기되고 심사가능성이 인정되면, 그 판결을 통상적인 확정판결과 완전히 같게 볼 수도 없다. 확정은 유지되지만, 그 효력작용은 헌법재판소의 가처분 또는 인용결정에 따라 달라질 수 있기 때문이다. 이 중간적 효력상태를 설명하는 데 먼저 참고할 수 있는 공법상 구조로서 행정행위의 공정력 및 취소소송의 집행부정지 구조를 들 수 있다.

행정처분은 당연무효가 아닌 한 위법사유가 있더라도 권한 있는 기관이나 쟁송절차에 의하여 취소되기 전까지 유효하게 통용되고, 취소소송의 제기만으로 그 효력이나 집행이 정지되지 않는다. 다만 법원은 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 집행정지를 명할 수 있고, 취소판결이 확정되면 행정청은 그 판결에 기속

29) 기판력과는 다른 사법상의 효과라는 점에서 반사효에 대해 독일의 학설사상 Kuttner의 체계화로 분석한 연구로서 이하 최건호, “확정판결의 반사효와 유사필수적 공동소송”, 『저스티스』 제86호, 한국법학원, 2005, 42-43면 참조.

된다.[30]

그러나 유동적 확정을 행정행위의 공정력으로 환원할 수는 없다. 공정력은 행정행위의 통용력에 관한 법리이고, 확정판결은 대심적 절차, 증거조사, 이유 제시, 상소 가능성 및 최종심 판단을 거친 사법적 판단이다. 따라서 확정판결에는 일반 행정처분보다 더 두터운 절차적 정당성과 합법성·헌법합치성에 대한 신뢰가 붙는다. 나아가 재판소원이 문제 삼는 것은 단순히 취소 전까지 통용되는 공권력 행사가 아니라, 형식적 확정력·기판력·집행력까지 갖춘 최종 사법판단이다. 이러한 점에 비추어 공정력 개념만으로는 재판소원이 제기된 확정판결의 효력상태를 충분히 설명할 수 없고, 별도의 분석개념이 필요하다.[31]

정리하자면 공정력 논의는 공법상 효력유지와 취소가능성의 구조를 보여 주고, 유동적 무효 법리는 과도적 효력상태를 절차조건과 종료사유로 설명하는 사고방식을 제공한다. 그러나 유동적 확정은 확정판결의 권위를 해체하거나 사실과 다른 상태를 의도적으로 간주하는 의제도 아니다.[32] 유동적 무효에서 차용하는 것은

30) 행정기본법 제15조; 행정소송법 제23조 제1항·제2항, 제30조 제1항; 사법연수원, 『법원실무제요 민사소송 I』, 48면; 박균성, 『행정법강의』 제23판, 박영사, 2026, 66-75면; 대법원 1987. 7. 7. 선고 87다카54 판결; 대법원 1994. 11. 11. 선고 94다28000 판결; 대법원 1999. 8. 20. 선고 99다20179 판결 참조.

31) 민사법상 유동적 무효 법리는 이 공백을 메우는 보조적 착상으로서 기능한다. 이는 1991년 전원합의체 판결 이후 계약금 반환, 확정적 무효 전환, 협력의무, 해제·손해배상 제한 등 반복되는 쟁점에서 적용·수정되어 온 판례법리이다. 물론 유동적 무효는 아직 효력이 완성되지 않은 계약이 장래 유효화될 수 있는 구조이고, 유동적 확정은 이미 성립한 확정판결의 효력작용이 장래 제한되거나 재구성될 수 있는 구조인 점에서 양자는 다른 방향을 바라본다. 따라서 여기서 차용하는 것은 결론이 아니라 사고 형식으로, 효력상태를 유효와 무효의 양자택일로만 보지 않고 현재의 효력상태와 장래의 효력변동 가능성을 절차적 조건 및 종료사유와 함께 설명하는 방식이다. 민사법상 유동적 무효 법리의 형성·전개에 관하여는 대법원 1991. 12. 24. 선고 90다12243 전원합의체 판결; 대법원 1993. 7. 27. 선고 91다33766 판결; 대법원 1997. 6. 27. 선고 97다9369 판결; 대법원 1997. 7. 25. 선고 97다4357, 4364 판결; 대법원 1998. 3. 27. 선고 97다36996 판결; 대법원 1999. 6. 17. 선고 98다40459 전원합의체 판결 참조.

32) 법적 의제의 기능과 한계에 관하여는 크리스틴느 비께(남궁술 역), "법에서의 의제(Les fictions en droit)", 『저스티스』 제134호, 한국법학원, 2013, 155-156면 참조. 실제라는 것은 결국 각인이 놓인 상황에서 특정 상태를 어떻게 바라보느냐에 따라 달리 인식될 수 있고, 이때 사안은 각기 다른 표현에 의거 별개의 사유체계를 구성

무효가 장래 유효화될 수 있다는 결론이 아니라, 현재의 효력상태와 장래의 효력변동 가능성을 절차적 조건 아래 함께 설명하는 사고 방식이다. 이 틀을 확정판결의 효력론에 적용하면, 재판소원이 제기된 확정판결은 미확정판결도 아니고 통상적 확정판결도 아닌, 효력작용이 절차적으로 조건화된 확정상태로 설명될 수 있다.

## 2. 유동적 확정의 정의와 법적 성질

확정재판을 대상으로 한 재판소원이 청구기간 등 적법요건을 갖추고, 제68조 제3항 각 호 사유와 명백히 무관하다고 보기 어려워 지정재판부 각하 단계에서 배제되지 않는 경우, 그 확정재판은 형식적 확정력과 기판력 등 구속효 및 원칙적 집행력을 유지한다. 그러나 헌법재판소의 가처분 또는 인용결정이 있으면 그 효력작용은 잠정 정지되거나, 해당 재판의 취소와 법원의 다시 재판으로 재구성될 수 있다. 이처럼 확정은 유지되지만 효력작용이 헌법소송 절차의 조건 아래 놓인 상태를 앞서 본 바와 같이 본고는 유동적 확정이라고 부른다.[33]

이 정의에서 확정의 유지와 효력작용의 조건화가 동시에 존재한다는 점이 중요하다. 형식적 확정력과 기판력은 원칙적으로 유지되고, 가처분이 없으면 집행력도 원칙적으로 유지된다. 다만 적법한 재판소원이 사전심사의 문턱을 넘을 수 있는 경우에는, 그 효력작용이 헌법재판소의 가처분 또는 인용결정에 따라 달라질 수 있다. 그래서 유동적 확정을 조건부 확정이라고 부르는 것은 적절하지 않다. 조건에 걸린 것은 확정 자체가 아니라 그 확정판결이 현실에서 작용하는 방식이기 때문이다.[34]

또한 유동적 확정은 재심절차가 본안으로 진행되는 경우와도 구별된다. 민사

---

할 수 있다. 이러한 시선에 따라, 본고의 유동적 확정은 사실과 다른 상태를 의제하는 개념이 아니라, 재판소원 절차가 만들어내는 효력상태를 설명하는 분석개념이다.

33) 헌법재판소법 제68조 제3항, 제71조의2, 제72조 제3항·제4항, 제75조 제4항. 이때 '심사가능성'이란 독자적 법정요건이 아니라, 제72조 제3항 제4호의 '제68조 제3항의 청구 사유에 해당하지 아니하는 것이 명백한 경우'를 유동적 확정의 발생 문턱으로 재기술한 분석개념이다.

34) 헌법재판소법 제71조의2 및 제75조 제4항. 제71조의2는 종국결정 선고 전까지 심판대상이 된 공권력의 효력정지를 가능하게 하고, 제75조 제4항은 법원 재판에 대한 인용결정의 효과를 해당 재판의 취소와 법원의 다시 재판으로 정한다.

재심은 확정된 종국판결에 판결절차 또는 소송자료의 중대한 흠이 있다는 주장, 법정 재심사유, 재심의 소, 법원의 적법요건·재심사유 심리를 거쳐 흠 있는 판결 전의 소송상태로 돌아갈 수 있는 절차이다. 반면 유동적 확정은 재심사유를 원인으로 법원이 자기 판결을 다시 심리하는 상태가 아니라, 확정재판이 제68조 제3항의 제한된 청구사유와 제72조 사전심사 구조를 통과해 헌법재판소의 심판대상으로 놓인 상태이다.[35]

이 명칭의 실익은 단계별 판단을 분리해 준다는 데 있다. 첫째, 청구기간 내에 적법한 재판소원이 제기되었으나 가처분이 없는 동안에는 확정력과 집행력이 유지된다는 점을 설명한다. 둘째, 지정재판부가 제72조 제3항 각하결정을 하지 않거나 제4항의 심판회부결정이 있는 것으로 보는 때에는, 단순 접수와 본안 심판계속을 구별하여 명백한 남용청구가 확정판결의 안정성을 흔드는 결과를 막는다. 셋째, 인용결정 후 법원이 다시 재판할 때에는 원판결이 언제부터 어떤 범위에서 효력작용을 잃는지, 제3자 관계와 이미 진행된 집행을 어떻게 조정할지의 출발점을 제공한다. 따라서 유동적 확정은 확정판결의 권위를 약화시키는 명칭이 아니라, 확정의 유지와 제한적 효력조정을 동시에 말하기 위한 분석개념이다.

나아가 이 개념은 어려운 사례에서 결론의 순서를 정해 줄 수 있다는 점에서도 실익이 있다. 예컨대 가처분 없이 확정판결에 기초한 집행이 끝난 뒤 재판소원이 인용되면, 집행 당시에는 자동정지효가 없어 집행력 행사가 곧바로 위법해지는 것은 아니다. 그러나 인용결정으로 해당 재판이 취소되면 이미 이전된 급부나 형성된 법률관계를 확정된 이익으로 둘 수 있는지는 다시 보아야 한다. 유동적 확정은 집행 당시의 효력유지와 인용 후 원상회복·부당이득·재재판상 조정을 구별하게 한다. 민사소송법 제215조의 가집행선고 실효·원상회복 구조처럼, 문제는 집행의 전면 무효가 아니라 인용 후 이익귀속과 회복범위이다. 또 30일 이내에 재판소원이 제기되었으나 심판회부 전 제3자가 등장한 경우에도 단순 확정판결 신뢰와 절차 위에 드러난 효력변동 가능성을 전제한 신뢰는 같지 않다. 다만 재판소원 계속은 등기처럼 공시되지 않으므로, 제3자에게는 직접 의존성, 인식 가능성, 선의·무과실, 후속 법률관계의 독자성을 고려한 한정적 조정이 필요하다.

35) 민사 재심의 기본 구조는 사법연수원, 『법원실무제요 민사소송 III』, 503면, 522-525면; 민사소송법 제451조, 제454조, 제456조 참조.

### 3. 유동적 확정의 발생요건

유동적 확정은 재판소원 제도 자체에서 자동으로 생기는 상태가 아니다. 30일 청구기간은 단순한 소송경제 규정에 그치지 않는다. 제69조 제1항 단서는 일반 권리구제형 헌법소원의 90일·1년 기간과 달리, 법원 재판에 대한 헌법소원은 확정일부터 30일 이내에만 허용한다. 이 설계는 확정재판을 헌법소원의 대상으로 열어 두되, 그 개방성을 짧게 제한하여 절차를 조속히 안정시키려는 것이다. 따라서 30일 이내와 30일 이후는 질적으로 구별된다.[36]

첫째, 대상은 확정재판이어야 한다. 헌법재판소법 제68조 제3항은 법원 재판에 대한 헌법소원의 대상을 "확정된 재판"으로 한정한다. 이 요건은 재판소원을 상소와 구별하게 한다. 상소는 확정 전 불복절차이고, 상소가 제기되면 재판의 확정이 차단된다. 반면 재판소원은 이미 확정된 재판을 헌법소송절차에서 문제 삼는 절차이다. 따라서 유동적 확정은 아직 확정되지 않은 상태가 아니라, 확정판결의 효력 변동 가능성이 헌법재판소 절차 위에 드러난 상태를 말한다.

둘째, 재판소원은 적법하여야 한다. 여기서 적법하다는 것은 청구기간, 보충성, 대리인 선임, 청구인 적격, 기본권 침해의 자기관련성 같은 헌법소원심판의 기본 요건을 갖추었다는 뜻이다. 특히 개정 헌법재판소법은 법원 재판에 대한 헌법소원을 확정일부터 30일 이내에 청구하도록 정한다. 이 기간을 넘긴 청구는 제72조

36) 다만 유동적 확정의 발생시점을 두고는 견해가 나뉠 수 있다. 형식설은 외부의 명백한 징표를 기준으로 삼는다. 그 안에서도 광의설, 즉 30일 기간설은 확정일부터 30일 동안의 모든 확정재판을 유동적 확정으로 본다. 청구제기설은 30일 이내에 재판소원이 실제 제기된 경우로 좁힌다. 심판회부설은 지정재판부 각하를 통과한 심판회부결정 또는 그 의제까지 요구한다. 반면 실질설은 외부 징표보다 청구내용의 실질, 곧 제68조 제3항 각 호 사유와의 관련성과 본안심사의 필요성을 중심으로 본다. 형식설은 기준이 명확하다는 장점이 있지만, 지나치게 넓게 잡으면 실제 재판소원이 제기되지 않은 압도다수 확정판결까지 불안정한 상태로 부르게 된다. 실질설은 남용청구를 걸러낼 수 있지만, 발생시점이 사후적으로 흐려질 위험이 있다. 따라서 본고는 절충설, 곧 형식적 현출·실질적 심사가능성 결합설을 취한다. 재판소원이 기간 내에 실제 제기되어 헌법재판소 절차 위에 현출되고, 그 청구가 제68조 제3항 각 호 사유와 명백히 무관하지 않은 최소한의 심사가능성을 가질 때 비로소 유동적 확정이 발생한다. 이는 형식설의 명확성과 실질설의 남용통제 기능을 함께 살리는 설명이다.

제3항 제2호의 각하사유가 되므로, 확정판결은 재판소원 절차의 조건 아래 놓이지 않는다. 기간 안의 청구라도 다른 적법요건을 갖추지 못하면 마찬가지다. 재판소원은 상소를 대신하는 절차가 아니므로, 통상적 구제절차를 거칠 수 있었는데도 이를 거치지 않은 청구도 유동적 확정을 발생시키지 않는다.

셋째, 심사가능성이 인정되어야 한다. 심사가능성이란 청구인의 주장을 사실로 보더라도 헌법재판소법 제68조 제3항 각 호 사유에 해당하지 아니하는 것이 명백하다고 할 수 없는 상태를 말한다. 본안에서 인용될 가능성이 높다는 뜻은 아니다. 청구인의 주장 자체가 각 호 사유와 무관하거나 단순한 사실인정·증거평가·법률해석 불복에 그치면, 제72조 제3항 제4호에 따라 지정재판부 각하사유가 된다. 반대로 지정재판부가 제72조 제3항의 각하결정을 하지 않거나 청구 후 30일이 지나 제4항의 심판회부결정이 있는 것으로 보는 때에는, 그때부터 대상 확정재판의 효력작용이 헌법재판소 절차의 결과에 의해 조건화될 수 있다.[37] 요건을 정리하면 <표 5>와 같다.

<표 5> 유동적 확정의 발생요건 — 세 요건 비교

| 요건 | 판단대상 | 핵심 판단 기준 | 흠결 시 효과 |
|---|---|---|---|
| 확정재판성 | 대상재판이 형식적으로 확정되었는가 | 상소 등 통상적 불복절차가 끝나 더 이상 다툴 수 없는 상태인지 | 재판소원이 상소와 구별되지 않음 → 재판소원 자체 불가 |
| 적법한 재판소원 | 청구가 기본적 적법요건을 갖추었는가 | 확정일부터 30일 이내 청구, 통상적 구제절차 경유, 청구인 적격·자기관련성·대리인 선임 등 | 유동적 확정 불발생 → 확정판결 효력상태 변화 없음 |
| 심사가능성 | 청구내용이 제68조 제3항 각 호 사유와 최소한 관련되는가 | 청구인의 주장을 사실로 보아도 각 호 사유와 명백히 무관하지 않은지. 단순 패소 불복, 사실인정, 증거평가, 법률해석 다툼은 제외 | 유동적 확정 불발생 → 남용 청구가 확정판결 안정성을 흔드는 결과 방지 |

37) 헌법재판소법 제25조, 제68조 제3항, 제69조 제1항 단서, 제72조 제3항·제4항. 제69조 제1항 단서는 법원 재판에 대한 헌법소원심판을 그 확정일부터 30일 이내에 청구하도록 정하고, 제72조 제3항은 청구기간 도과, 구제절차 미경유, 대리인 흠결, 재판소원 청구사유의 명백한 부존재 등을 지정재판부 각하사유로 정한다.

심사가능성은 남용 청구가 확정판결을 흔드는 것을 방지하는 기능수행을 한다. 단순 접수만으로 유동적 확정을 인정하면, 명백히 부적법한 청구도 확정판결의 효력상태를 흔들 수 있다. 반대로 본안 인용 가능성이 거의 확실한 경우에만 유동적 확정을 인정하면, 가처분이나 사전심사 단계의 효력문제를 설명하기 어렵다. 그래서 심사가능성은 단순 접수와 본안 인용 사이의 중간 기준으로 기능한다. 그 독자성은 새로운 법정요건을 세우는 데 있는 것이 아니라, 제72조 제3항 제4호의 소극적 각하 기준을 확정판결 효력론의 발생 문턱으로 전환해 읽는 데 있다. 이 문턱을 두어야 단순 접수, 심판회부, 본안 인용의 효력상태를 서로 구별할 수 있다.[38]

제68조 제3항 제1호 사건에서는 법원의 재판이 헌법재판소 결정에 반하는 취지로 이루어져 기본권을 침해한 경우를 말하는 이상, 심사가능성을 더 구체적으로 판단해야 한다. 먼저 선행 헌법재판소 결정이 실제로 있어야 한다. 다음으로 그 결정의 주문과 핵심 이유가 어떤 규범 의미를 배제하거나 어떤 헌법적 기준을 세웠는지 확인해야 한다. 그 다음 대상 법원 재판이 어떤 규범전제 위에서 내려졌는지 특정해야 한다. 마지막으로 그 규범전제가 선행 결정의 주문 또는 핵심 이유와 실질적으로 충돌하고, 그 충돌이 청구인의 기본권 침해로 이어졌는지 보아야 한다.[39] 이 가운데 어느 하나라도 명백히 빠지면 심사가능성은 인정되기 어렵다. 나아가 선행 결정이 없거나, 선행 결정이 배제한 규범 의미와 대상 법원 재판의 규범전제가 실질적으로 같지 않거나, 대상재판이 단순히 법률해석상 다른 견해를 취한 데 그친다면 제1호 사건의 심사가능성은 없다. 헌법재판소 결정과 법원 재판

38) 김하열, 앞의 글(주 5), 331-332면. 헌법재판에서 기본권 침해 판단이 사실인정과 법적 평가를 함께 요구하고, 심판유형별 본안판단에서 증명책임 문제가 달라진다는 점을 설명한다. 나아가 심사가능성은 발생시점과 확인시점을 구별해 이해해야 한다. 유동적 확정은 청구 제기라는 외부 징표를 계기로 문제되지만, 성립 여부는 지정재판부 각하 여부, 심판회부결정 또는 그 의제, 본안 심리 가능성을 통해 사후적으로 확인되기 때문이다. 만약 청구기간 도과, 보충성·대리인 흠결 또는 제68조 제3항 청구사유의 명백한 부존재로 각하되면, 유동적 확정이 발생하였다가 소멸한 것이 아니라 처음부터 성립하지 않은 것이다. 반대로 기간 안의 적법한 청구가 사전심사 문턱을 통과할 심사가능성을 가지면, 그 효력변동 가능성은 청구 제기 시점부터 헌법재판소 절차 위에 현출된 것으로 평가할 수 있다. 결국 발생은 형식적 현출과 실질적 심사가능성의 결합으로, 확인은 사전심사와 심판회부 구조를 통해 정리된다.

39) 허완중, 앞의 글(주 26), 338-339면.

사이에 추상적 긴장이 있더라도, 그것이 청구인의 기본권 침해로 이어지지 않는 경우도 마찬가지다.[40][41]

예컨대 확정일부터 30일이 지난 뒤 제기된 재판소원은 청구기간 흠결 때문에 유동적 확정을 발생시키지 않는다. 30일 이내에 제기되었더라도 통상적 구제절차를 거치지 않았으면 보충성 흠결이 된다. 청구기간과 보충성 등 형식적 적법요건을 갖추었더라도, 청구인의 주장 자체가 제68조 제3항 각 호 사유와 명백히 무관하면 심사가능성이 없으므로 유동적 확정은 발생하지 않는다.

정리하면, 유동적 확정의 발생요건은 엄격하다. 대상이 확정재판이어야 하고, 재판소원이 적법하여야 하며, 제68조 제3항 각 호 사유에 관한 심사가능성이 인정되어야 한다. 어느 하나라도 빠지면 유동적 확정은 발생하지 않는다. 이 개념은 재판소원 제도를 넓히기 위한 장치가 아니다. 확정판결의 효력을 원칙적으로 유지하면서, 적법한 재판소원과 심사가능성이 인정되는 예외적 국면에서만 효력작용의 조건화를 설명하기 위한 통제 개념으로 작동한다.

## 4. 유동적 확정의 효력별 작동

유동적 확정 개념 논의의 출발점은 확정판결의 효력이 원칙적으로 유지된다는 데 있다. 다만 적법한 재판소원이 제기되고 심사가능성이 인정되면, 그 효력작용은 헌법재판소법상 가처분, 인용결정, 해당 재판의 취소와 법원의 다시 재판 구조에 따라 제한될 수 있다. 이하에서는 형식적 확정력, 기판력, 집행력, 제3자 관계를 나누어 본다.

---

40) 이는 본고의 제1호 사건 심사가능성 판단틀이다. 제1호는 법률해석 일반을 다시 심사하는 통로가 아니라, 헌법재판소 결정의 기속력과 충돌하는 법원 재판을 예외적으로 걸러내는 기준이다.

41) 이 기준은 한정위헌결정의 기속력 논쟁에도 적용될 수 있다. 한정위헌결정의 기속력을 전면 부정하면 헌법재판소가 배제한 위헌적 규범 의미를 법원이 다시 적용하는 경우를 통제하기 어렵다. 반대로 결정 이유 전체를 법원에 직접 구속한다고 보면 법원의 법률해석권을 지나치게 제한할 수 있다. 생각건대 제1호 사건에서는 결정주문을 중심으로 보되, 그 주문의 의미를 구성하는 핵심 이유를 함께 읽어야 한다. 이하 김시철, “우리 위헌법률심판제도와 헌법재판소 결정의 효력”, 『저스티스』 제90호, 한국법학원, 2006, 33-36면; 이동훈, 앞의 글(주 28), 115-118면 참조.

첫째, 형식적 확정력은 유지된다. 재판소원은 상소가 아니므로, 청구가 제기되었다고 해서 대상 재판이 미확정판결로 돌아가지 않는다. 대상 재판은 여전히 확정판결이다. 이 점을 흐리면 재판소원은 곧바로 4심처럼 보이게 된다. 둘째, 기판력도 원칙적으로 유지된다. 재판소원이 제기되었다는 사실만으로 확정판결의 소송물 판단이 당사자와 후소법원을 구속하는 힘이 사라지지는 않는다. 따라서 재판소원 계속 중에도 당사자와 후소법원은 원칙적으로 그 확정판결을 전제로 행동해야 한다. 다만 기판력 있는 판결이라고 해서 그 효력작용이 항상 같은 방식으로 끝까지 유지되는 것은 아니다. 적법한 재판소원과 심사가능성이 인정되고, 헌법재판소가 가처분을 발령하거나 본안에서 인용결정을 하면 그 결정이 미치는 범위에서 효력작용이 잠정적으로 제한되거나 재구성될 수 있다. 이 점에서 유동적 확정은 기판력의 소멸이 아니라, 기판력 있는 확정판결의 효력작용이 절차적으로 조건화되는 상태이다. 특히 제68조 제3항 제1호 사건에서는 이 구조가 더 분명하다. 헌법재판소가 다시 보는 것은 법원 재판의 모든 사실인정과 법률해석이 맞았는지가 아니다. 핵심은 대상 법원 재판이 선행 헌법재판소 결정에 반하는 취지로 이루어져 청구인의 기본권을 침해했는지이다. 따라서 확정판결의 기판력은 원칙적으로 유지되지만, 그 재판이 헌법재판소 결정의 기속력과 충돌하는 범위에서는 헌법재판소 결정에 따른 효력조정이 가능하다.

셋째, 집행력도 자동으로 정지되지 않는다. 재판소원 제기 자체에 자동정지효를 인정하면 재판소원은 사실상 상소와 비슷한 효과를 갖게 된다. 그러나 개정 헌법재판소법은 자동정지를 택하지 않았다. 법은 가처분 규정을 별도로 두고, 헌법재판소가 필요하다고 인정하는 경우에만 종국결정 선고 전까지 심판대상 공권력의 효력을 정지할 수 있게 한다. 따라서 재판소원이 제기되었다는 사실만으로 대상 확정판결에 기초한 집행이 당연히 멈추는 것은 아니다. 그러나 집행력이 원칙적으로 유지된다는 말이 집행위험이 없다는 뜻은 아니다. 적법한 재판소원과 심사가능성이 인정된 확정판결에 기초한 집행은 겉으로는 일반 확정판결에 기초한 집행과 같다. 하지만 그 안에는 가처분이나 인용결정에 따라 효력작용이 달라질 가능성이 들어 있다. 이 가능성은 일반 확정판결의 추상적 재심가능성과 다르다. 이미 헌법재판소 절차 위에 드러나 있고, 가처분 신청과 본안심사의 경로가 열려 있기 때문이다.[42]

넷째, 제3자 관계는 더 조심해서 보아야 한다. 확정판결의 효력은 원칙적으로 당사자 사이에서 작동한다. 그러나 일정한 경우에는 변론종결 후 승계인이나 판결과 실체법상 의존관계에 있는 제3자에게도 영향을 미친다. 민사소송법은 변론종결 후 승계인에게 확정판결의 효력이 미친다고 정하고, 판결의 제3자적 효력이나 반사효도 기판력과 구별되는 문제로 논의되어 왔다.[43] 재판소원 인용으로 해당 재판이 취소되면, 그 재판을 기초로 형성된 후속 법률관계도 영향을 받을 수 있다. 그러나 이미 형성된 모든 제3자 관계를 일률적으로 소급하여 무효로 돌리면 법적 안정성과 거래안전이 지나치게 침해된다. 재재판(再裁判) 법원이 기존 법질서 안에서 시간적·관계적 한계를 두고 조정해야 할 영역이 남는 만큼[44] 그 조정에서는 재판소원이 적법하게 제기되어 효력변동 가능성이 절차적으로 드러난 시점, 해당 확정판결의 효력에 직접 의존한 법률관계인지 여부, 이해관계인의 선의와 무과실, 재판소원 계속 사실에 대한 인식 가능성, 후속 법률관계의 독자성, 공익상 필요 등을 함께 보아야 한다.

유동적 확정의 효력별 작동을 정리하면 다음과 같다. ⓐ형식적 확정력은 유지된다. ⓑ기판력도 원칙적으로 유지된다. ⓒ집행력 역시 재판소원 제기만으로 자동 정지되지 않는다. ⓓ다만 가처분이 발령되면 그 범위에서 효력 또는 집행작용이 잠정적으로 제한되고, 본안에서 인용결정이 내려지면 해당 재판은 취소되어 법원의 다시 재판으로 이어진다. ⓔ그 뒤 제3자 관계와 후속 법률관계는 일률적 소급무효가 아니라 시간적·관계적 한정 처리로 조정되어야 한다. 결국 유동적 확정 개념은 확정판결의 효력을 층별로 보존하면서, 헌법재판소법이 정한 예외적 절차에 따라 효력작용이 재구성될 수 있음을 설명하는 개념이다.

---

42) 헌법재판 가처분의 잠정성과 본안 선취 위험을 지적하면서, 명시적 근거와 신중한 운용이 필요하다고 설명하는 견해로는 이준상, 앞의 글(주 11), 170-172면 참조.

43) 최건호, 앞의 글(주 29), 43-44면.

44) 고준성, “변론종결 후 승계인에 대한 신소 제기와 기판력”, 『법학연구』 제34권 제4호, 충남대학교 법학연구소, 2023, 422-423면; 유병현, “화해권고결정의 기판력이 미치는 승계인의 범위와 가처분의 효력”, 『저스티스』 통권 제126호, 한국법학원, 2011, 182-184면 참조. 두 논문은 변론종결 후 승계인과 가처분이 제3자 관계에서 기판력 작용을 제한하거나 조정하는 방식을 다룬다.

## 5. 유동적 확정의 종료

유동적 확정은 적법한 재판소원과 심사가능성 때문에 효력변동 가능성이 헌법재판소 절차 위에 올라온 상태일 뿐, 절차가 끝나면 그 상태도 끝난다. 이때 종료의 결과는 크게 두 가지다. 청구가 받아들여지지 않으면 대상 판결은 통상적 확정판결로 다시 안정된다. 청구가 인용되면 해당 재판이 취소되고 법원의 다시 재판 단계로 넘어간다. 이를 상술하면 다음과 같다.

첫째, 지정재판부가 각하하면 유동적 확정은 더 이상 문제되지 않는다. 헌법재판소법 제72조 제3항은 청구기간 도과, 구제절차 미경유, 대리인 흠결, 재판소원 청구사유의 명백한 부존재 등 일정한 사유가 있으면 지정재판부가 전원 일치 의견으로 헌법소원심판청구를 각하하도록 정한다. 다만 각하의 의미는 사유에 따라 나누어 보아야 하는바, 생각건대 청구기간 도과, 보충성 흠결, 대리인 흠결, 재판소원 사유의 명백한 부존재처럼 하자가 분명한 경우에는 처음부터 유동적 확정이 발생하지 않았다고 보는 것이 타당하다. 이때 각하결정은 이미 생긴 상태를 장래적으로 끝내는 결정이 아니라, 그런 상태가 없었다는 점을 확인하는 결정이다.[45]

둘째, 본안에서 기각결정이 내려지면 유동적 확정은 종료되고 대상 확정판결은 재안정화된다. 기각결정은 청구가 적법하게 본안심사의 대상이 되었지만, 헌법재판소법 제68조 제3항 각 호 사유가 인정되지 않는다는 판단이다. 이 경우 대상 판결은 헌법적 하자가 인정되지 않은 확정판결로 남는다. 따라서 그 판결의 형식적 확정력, 기판력, 집행력은 더 이상 헌법재판소 절차에 의해 조건화된 상태에 있지 않다. 여기서 재안정화는 새로운 효력을 만들어 낸다는 뜻이 아니다. 기각결정 전에도 확정판결의 효력은 원칙적으로 유지되고 있었다. 다만 적법한 재판소원과 심사가능성 때문에 효력변동 가능성이 절차적으로 드러나 있었을 뿐이다. 기각결정은 그 가능성을 닫고, 대상 판결을 통상적 확정판결의 효력상태로 되돌리는 기능을 한다.

45) 이때 사전심사가 일정 기간 진행되다가 각하되는 경우도 결론은 같다. 외형상 사건이 계속되었더라도, 각하결정은 청구가 본안심사 문턱을 넘지 못한다는 판단이다. 따라서 그 기간은 유동적 확정이 실제로 지속된 기간이라기보다, 발생 여부가 절차적으로 확인되기 전의 불확정 구간으로 보는 것이 정확하다.

셋째, 가처분은 본안결정 전의 임시 조치다. 헌법재판소법 제71조의2에 따른 가처분은 종국결정 선고 전까지 심판대상 공권력의 효력 또는 집행작용을 잠정적으로 조정하는 수단이다.[46] 따라서 본안결정이 내려지면 가처분은 그 결정의 내용에 흡수되거나 소멸한다. 청구가 각하되거나 기각되면 가처분의 근거가 되는 재판소원 절차의 효력변동 가능성이 사라지므로, 가처분도 더 이상 독립적으로 유지될 수 없다. 반대로 본안에서 인용결정이 내려지면 가처분은 재판취소와 다시 재판 구조로 흡수된다.

넷째, 인용결정이 내려지면 유동적 확정은 재판취소와 법원의 다시 재판 단계로 전환된다. 헌법재판소법 제75조 제4항은 침해의 원인이 된 공권력 행사가 법원의 재판인 때 헌법재판소가 해당 재판을 취소하고, 법원이 그 결정 취지에 따라 다시 재판하여야 한다고 정한다. 따라서 인용결정 선고 시점에 해당 재판은 취소되고, 같은 시점에 유동적 확정상태도 종료된다. 30일 청구기간의 도과는 종료 문제가 아니라 비발생 문제이다. 헌법재판소법 제69조 제1항 단서는 법원 재판에 대한 헌법소원을 그 확정일부터 30일 이내에 청구하도록 정한다. 이 기간은 확정판결을 헌법소원으로 문제 삼을 수 있는 시간적 개방성을 만들지만, 동시에 그 개방성을 신속히 닫는 한계이기도 하다. 기간 내에 재판소원이 제기되지 않으면 대상 확정판결은 유동적 확정상태로 진입하지 못하고, 30일 이후에는 제72조 제3항 제2호의 각하 구조에 의해 통상적 확정상태로 안정된다. 그 뒤의 구제 문제는 형벌법규 위헌결정 후 재심청구권처럼 법이 따로 정한 절차나 일반소송법상 재심 가능성의 문제로 넘어간다. 따라서 30일 도과 후의 확정판결 효력문제는 본고의 유동적 확정과 층위를 달리한다.

요컨대 유동적 확정의 종료는 두 방향으로 나뉜다. 각하 또는 기각이면 확정판결은 통상적 확정판결로 재안정화된다. 인용이면 대상재판이 취소되고 법원의 다시 재판 단계로 넘어간다. 가처분은 본안결정 전의 잠정적 조치이므로, 본안결

46) 헌법재판소법 제47조 제4항, 제69조 제1항 단서, 제71조의2, 제72조 제3항·제4항, 제75조 제4항; 이준상, 앞의 글(주 11), 164-166면 참조. 제69조와 제72조는 청구기간 및 지정재판부 각하·심판회부 구조를, 제71조의2는 종국결정 선고 전 가처분을, 제75조 제4항은 인용결정 때 재판취소와 법원의 다시 재판을 정한다. 제47조 제4항은 형벌법규 위헌결정 후 재심청구권을 별도로 둔다. 이준상은 헌법재판 가처분의 잠정적 권리보호 기능과 권력분립상 신중 운용 필요성을 설명한다.

정에 따라 소멸하거나 그 결정의 효과에 흡수된다.[47] 결국 유동적 확정은 발생요건만큼 종료요건도 중요하다. 발생요건이 명백한 남용청구를 걸러 낸다면, 종료요건은 효력변동 가능성이 무기한 남는 것을 막는다. 이 두 장치가 함께 작동할 때 유동적 확정은 재판소원의 4심화를 막으면서도 헌법적 권리구제의 실효성을 설명하는 효력상태론으로 기능할 수 있다.

## 6. 재심과의 구별: 잠재적 가능성과 절차적으로 현출된 가능성

재심과 유동적 확정은 같은 '확정 후 불복'의 외형을 가지지만, 원인과 효과가 다르다. 민사소송법 제451조는 확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있는 사유를 열거하고, 그 단서는 상소에서 주장했거나 알고도 주장하지 않은 사유를 재심으로 다시 들 수 없게 한다. 따라서 재심에서 문제 되는 불안정성은 확정판결 자체에 늘 붙어 있는 추상적 가능성이 아니라, 법정 재심사유가 주장되어 법원절차 안에서 심리되는 가능성이다.

심사 단계를 맞추어 보아도 차이는 남는다. 재심절차에서 법원은 재심의 소의 적법 여부와 재심사유의 존부를 먼저 분리하여 심리할 수 있고, 재심사유가 있다고 인정하면 그 취지의 중간판결 뒤 본안에 관하여 심리·재판한다. 이 단계에서도 심리의 원인은 민사소송법 제451조의 재심사유이고, 심판기관은 그 판결을 한 법원 계통이다. 반면 재판소원에서 유동적 확정은 재심사유가 아니라 제68조 제3항 각 호 사유, 제69조 청구기간, 제72조 사전심사와 심판회부결정, 제71조의2 가처분, 제75조 제4항의 재판취소와 다시 재판 구조가 결합되어 생기는 헌법소송절차상 상태이다. 만약 재판소원이 재심과 같은 절차라면, 확정일부터 30일이라는 별도 단기 청구기간을 둘 이유가 약해진다. 재심은 법정 재심사유라는 사후적·예외적 하자가 주장될 때 법원절차 안에서 다시 열리는 구조이다. 반면 재판소원은 확정 직후의 짧은 기간 내에 헌법소원 가능성을 열어 두고, 사전심사와 심판회부를 통해 그 가능성을 빠르게 정리한다. 그러므로 30일은 재심과의 구별표지이자

47) 이때의 종료는 유동적 확정의 자기제한 기능을 강화한다. 유동적 확정은 확정판결을 오래 불안정하게 두기 위한 개념이 아니다. 언제 발생하는지뿐 아니라 언제 끝나는지를 함께 정해야, 재판소원이 확정판결의 안정성을 과도하게 흔드는 것을 막을 수 있다.

유동적 확정의 시간적 경계이다.

헌법재판소법 제75조 제4항·제8항·제9항도 이 차이를 문언으로 나누어 둔다. 제68조 제2항 헌법소원이 인용되고 관련 소송사건이 이미 확정된 경우에는 당사자가 재심을 청구할 수 있고, 그 재심에는 민사소송법 또는 형사소송법이 준용된다. 반면 법원 재판에 대한 헌법소원이 인용된 경우에는 헌법재판소가 해당 재판을 취소하고, 법원이 그 결정 취지에 따라 다시 재판한다. 따라서 유동적 확정은 재심가능성 일반이 아니라, 재판소원 계속 중 확정판결의 효력작용이 헌법재판소 절차의 조건 아래 놓인 상태를 가리킨다.

## 7. 보론: 인접개념과의 구별

유동적 확정은 미확정상태, 상소계속상태, 재심, 비상상고, 단순한 가처분 또는 집행정지와 다르다. 첫째, 상소는 재판이 확정되기 전에 상급법원에 취소나 변경을 구하는 통상적 불복절차라는 점에서 다르다. 상소가 제기되면 재판의 확정은 차단된다.[48] 상소심은 하급심 재판의 당부를 심사하지만, 재판소원은 이미 확정된 재판을 대상으로 한다. 심사대상도 헌법재판소법 제68조 제3항 각 호 사유에 한정된다. 재판소원은 사실인정, 증거평가, 법률해석 전반을 다시 보는 상소심이 아니다. 특히 제1호 사건에서는 대상재판이 선행 헌법재판소 결정에 반하는 취지로 이루어져 기본권을 침해하였는지가 문제된다. 이 차이는 4심화 방지 기능과 연결된다. 재판소원이 상소와 같다면 청구 제기만으로 확정이 차단되거나 확정판결의 효력이 전면 정지되어야 한다. 그러나 개정 헌법재판소법은 그렇게 설계되어 있지 않다. 대상은 확정된 재판이고, 청구기간은 30일로 제한된다. 또 지정재판부 사전심사, 가처분, 인용 시 재판취소와 다시 재판 구조가 함께 작동한다. 따라서 재판소원은 상소의 추가심급이 아니라 확정판결의 헌법적 한계상황을 다루는 제한적 헌법소송절차이다.

48) 강현중, 앞의 글(주 3), 70-71면. 강현중은 상소가 확정 전 불복절차이고 재심은 확정 후 불복절차라는 점을 구별한다. 헌법재판소, “확정된 법원의 재판에 대한 헌법소원 심판 도입 안내”, 2026, 1면도 재판소원이 사실관계 인정이나 법률의 개별적 포섭·적용에 대한 불복절차나 재심절차가 아니라고 설명한다.

둘째, 재심의 본안 심리가 열릴 수 있는 경우에도 그 원인은 법정 재심사유이고, 법원은 재심청구이유의 범위 안에서 재심대상판결의 취소와 다시 종국판결을 판단한다. 반면 유동적 확정은 법원이 재심사유를 심리하는 상태가 아니라, 확정재판이 헌법재판소의 사전심사를 거쳐 제한적 헌법심판의 대상이 된 상태이다. 그러므로 두 절차는 모두 확정 후에 문제 되지만, 하나는 법원절차 내부의 하자시정이고 다른 하나는 헌법재판소법상 재판소원의 효력조정이다.

셋째, 비상상고는 판결이 확정된 뒤 그 심판이 법령에 위반한 경우 검찰총장이 대법원에 시정을 구하는 절차로서 재심이 중대한 사실인정 오류를 시정하여 판결을 받은 사람의 이익을 구제하는 절차라면, 비상상고는 법령해석과 적용의 통일을 중심에 둔다.[49] 반면 재판소원은 청구인의 기본권 침해를 전제로 하는 헌법소원심판이다. 목적도 법령해석의 추상적 통일이 아니라 확정재판의 헌법적 하자와 그로 인한 기본권 침해를 심사하는 데 있다.

넷째, 가처분이나 집행정지는 본안 판단 전까지 효력 또는 집행작용을 임시로 조정하는 수단이다. 그 자체가 확정판결의 효력상태를 설명하는 개념은 아니다. 반면 유동적 확정은 적법한 재판소원과 심사가능성이 있는 동안 확정판결의 효력작용이 헌법재판소 절차의 조건 아래 놓이는 상태를 설명한다. 따라서 가처분은 유동적 확정에서 나타날 수 있는 효과일 수는 있어도, 유동적 확정 자체와 같지 않다.

## Ⅴ. 비교법적 시사점

### 1. 독일: 재판헌법소원의 효력구조

독일의 헌법소원은 공권력으로 기본권을 침해받았다고 주장하는 개인에게 열려 있다. 법원의 재판도 대상이 될 수 있다. 그러나 아무 재판이나 다시 다투는 절차는 아니다. 원칙적으로 통상적 권리구제절차를 모두 거친 뒤에만 제기할 수

49) 형사소송법 제441조; 권오걸, “재심과 비상상고의 교차영역”, 『법학논고』 제81호, 경북대학교 법학연구원, 2023, 252-255면. 제441조는 판결 확정 후 심판의 법령위반을 비상상고이유로 정한다. 권오걸은 재심은 사실오인 시정을 통한 피고인 구제, 비상상고는 법령해석·적용의 통일과 피고인 구제를 중심으로 설명한다.

있고, 심사대상도 하급심 재판의 사실인정이나 법률해석 일반이 아니라 기본권 침해 여부이다. 독일 연방헌법재판소의 이른바 헤크(Heck) 공식도 같은 방향이다. 사실관계 확정, 증거평가, 일반 법률해석·적용은 원칙적으로 일반법원의 몫이고, 연방헌법재판소는 일반법원이 '특수한 헌법'을 위반한 경우에 한하여 개입한다.[50] 나아가 연방헌법재판소법 제93a조는 헌법소원이 재판부의 판단을 받으려면 수리되어야 한다고 정하고 있고, 이때의 수리 사유는 기본적 헌법적 의의가 있거나 기본권 관철을 위해 필요한 경우로 제한된다. 이 수리절차는 재판헌법소원이 모든 패소사건의 추가심급으로 바뀌는 것을 막는 장치로서 기능한다.[51]

한국의 2026년 재판소원 제도에서 지정재판부 사전심사가 하는 기능도 이와 닮아 있다. 한국법은 독일식 수리절차를 그대로 받아들이지는 않는다. 그러나 청구기간 도과, 구제절차 미경유, 재판소원 청구사유의 명백한 부존재 등을 사전심사 단계에서 걸러 낸다. 이 장치는 재판소원이 단순한 패소불복으로 남용되는 것을 막고, 헌법소송절차로서의 성격을 유지하게 한다.

독일 제도의 시사는 인용결정의 효과에서 더 분명해진다. 연방헌법재판소법 제95조 제2항은 법원 결정에 대한 헌법소원이 인용되는 경우, 연방헌법재판소가 그 결정을 취소하고 일정한 경우 사건을 관할 법원으로 환송하도록 정한다.[52] 이는 헌법재판소가 일반법원의 재판기능을 전면 대체한다는 뜻이 아니다. 기본권

---

50) 독일 연방헌법재판소법(BVerfGG) 제90조 제1항·제2항. 제1항은 공권력에 의한 기본권 침해 주장을 헌법소원의 대상으로 정하고, 제2항은 권리구제절차가 열려 있으면 원칙적으로 그 절차를 거친 뒤 제기하도록 한다. 이때 재판소원에서 연방헌법재판소의 개입 기준으로서의 헤크(Heck) 공식은, 일반법원에 대한 재판소원 사건에서 연방헌법재판소의 심사범위에 관한 기준을 정립한 결정이다. 이 사건의 주심 재판관이었던 헤크(Heck)의 성함을 따서'헤크 공식'으로도 명명된다. 독일 재판소원의 심사범위를 정리한 헤크 공식에 관하여는 이지효, "독일 재판소원에서 연방헌법재판소의 개입 기준으로서의 헤크(Heck) 공식",『세계헌법재판 조사연구보고서』2026년 제1호, 헌법재판연구원, 2026, 9-11면.

51) 독일 연방헌법재판소법 제93a조 제1항·제2항 및 제93b조. 제93a조는 헌법소원이 재판을 받기 위해 수리되어야 한다고 정하고, 기본적 헌법적 의의 또는 기본권 관철 필요성을 수리 사유로 둔다. 제93b조는 수리 여부 결정 구조를 정한다.

52) 독일 연방헌법재판소법 제95조 제2항. 이 조항은 법원 결정에 대한 헌법소원이 인용되는 경우 연방헌법재판소가 그 결정을 취소하고, 일정한 경우 사건을 관할 법원으로 환송하도록 정한다.

침해가 있는 재판을 취소하고, 구체적 사건의 재판은 다시 전문법원에 맡기는 구조이다. 이 점은 한국 재판소원 제도의 재판취소 후 재재판이라는 구조와 기능적으로 평행한다. 한국 헌법재판소법 제75조 제4항도 법원의 재판이 기본권 침해의 원인인 때 헌법재판소가 해당 재판을 취소하고, 법원이 헌법재판소 결정 취지에 따라 다시 재판하도록 한다. 두 제도 모두 헌법재판기관이 일반법원의 재판을 전면적으로 대체하지 않고, 오직 헌법적 하자를 제거하고, 구체적 사건의 재판 기능은 다시 법원으로 돌려보낸다.[53]

독일법이 "유동적 확정"이라는 개념을 명문으로 두는 것은 아니다. 다만 독일 제도는 확정재판을 헌법소원의 대상으로 삼으면서도 4심화를 통제할 수 있음을 보여준다. 그 장치는 심사범위 제한, 권리구제절차 소진, 수리절차, 임시명령, 취소와 환송 구조이다. 이에 비춰, 독일 비교법의 시사는 다음 세 가지로 정리될 수 있다. 첫째, 재판헌법소원은 재판을 대상으로 하더라도 심사범위를 기본권 침해에 한정하면 상소와 구별된다. 둘째, 인용의 효과를 헌법재판기관의 전면적 재판대체가 아니라 재판취소와 환송 또는 다시 재판 구조로 설계하면, 법원의 재판권과 헌법재판의 실효성을 함께 보존할 수 있다. 셋째, 임시명령 또는 가처분은 자동정지효가 아니라 예외적 잠정조치로 운용되어야 한다.

결국 독일 제도는 재판소원이 곧 4심을 뜻하지 않는다는 점을 보여준다. 핵심은 재판소원의 존재 여부가 아니라 심사범위와 효력구조를 어떻게 제한하고 조정하는가이다. 한국법의 유동적 확정 개념은 이 지점에서 비교법적 정당성을 얻는다. 확정판결은 유지된다. 그러나 적법한 재판소원과 심사가능성이 인정되면 효력변동 가능성은 헌법재판소 절차 위에 드러나고, 가처분 또는 인용결정에 따라 효력작용이 조건화될 수 있다.

---

53) 보론: 구속력도 주목할 필요가 있다. 독일 연방헌법재판소법 제31조 제1항은 연방헌법재판소의 결정이 연방과 주의 헌법기관, 모든 법원과 행정청을 구속한다고 정한다. 따라서 연방헌법재판소가 전문법원 판결을 기본법 위반으로 취소하고 환송하면, 환송 후 전문법원은 그 기본권 침해 판단에 구속된다. 취소된 재판을 다시 기본법에 합치한다고 판단할 수 없다. 임시명령도 독일 제도의 조정장치다. 연방헌법재판소법 제32조 제1항은 중대한 불이익의 방지, 급박한 폭력의 방지 또는 그 밖의 중대한 공익상 이유가 있는 경우 임시명령을 발령할 수 있도록 정한다. 이에 비해 한국 헌법재판소법 제71조의2는 "필요하다고 인정하는 경우"라는 더 추상적인 요건을 둔다. 따라서 한국의 가처분은 예측 가능성은 낮지만 운용 재량은 더 넓다.

## 2. 미국: 보충적 시사

미국 연방법상 확정 형사판결에 대한 사후 구제는 직접상소가 끝난 뒤 별도의 collateral review로 이루어진다. 주 법원 판결에 따른 구금자는 28 U.S.C. §2254에 따라 연방 헌법·법률·조약 위반을 이유로 habeas corpus를 신청할 수 있고, 연방 형사판결의 수형자는 28 U.S.C. §2255에 따라 선고 법원에 판결 또는 형의 취소·변경을 구하는 신청을 할 수 있다.[54] 그러나 이 절차는 확정판결을 다시 미확정으로 돌리는 통상적 심급이 아니다. 권리구제절차 소진, 제척기간, 재심사 범위 제한이 작동하고, Teague 법리는 새 형사절차상 헌법규칙이 원칙적으로 확정사건의 collateral review에 소급 적용되지 않는다고 본다.[55] 따라서 미국 제도는 재판소원과 직접 비교할 모델이라기보다, 확정 후 헌법구제가 확정판결 자체의 미확정화를 뜻하지 않는다는 점을 보여주는 보충적 시사에 그친다.

## 3. 일본: 재판소원 부재 모델과의 대조

일본법은 독립한 헌법재판소나 헌법소원형 재판통제 절차를 두지 않는다. 일본 국헌법 제81조는 최고재판소를 위헌심사의 종심재판소로 두고, 재판소법은 그 관할을 상고와 법률상 항고 등으로 구성한다. 그래서 헌법문제도 구체적 사건의 상소·항고 안에서 다루어진다. 확정재판을 별도 헌법소원심판 대상으로 다시 가져가는 구조가 아니므로, 일본 모델에서는 '유동적 확정'이라는 별도 효력상태론이 생기지 않는다.[56]

---

54) 28 U.S.C. §2254(a), (b)(1); 28 U.S.C. §2255(a), (f). 제2254조는 주 법원 판결에 따른 구금자의 연방 habeas corpus 신청 구조와 권리구제절차 소진 요건을 정하고, 제2255조는 연방 형사판결 수형자의 선고 법원에 대한 판결·형 취소 또는 변경 신청과 1년 제척기간을 정한다.

55) Teague v. Lane, 489 U.S. 288, 310 (1989). Teague 법리는 새 형사절차상 헌법규칙이 원칙적으로 직접심사가 종료된 확정사건의 collateral review에 소급 적용되지 않는다는 점을 밝힌다.

56) 손인혁, "동아시아에서 헌법재판의 현황 및 문제점과 그 시사점", 『저스티스』 통권 제158-2호, 2017, 379-385면.

## 4. 한국법의 모델적 위치

앞의 비교법 검토를 종합하면, 한국의 2026년 재판소원 제도는 독일식 재판헌법소원을 그대로 수용한 것도 아니고, 미국식 collateral review와 같은 확정 후 부수심사 구조를 취한 것도 아니며, 일본식 재판소원 부재 모델에 머무는 것도 아니다. 한국법은 독립형 헌법재판기관을 전제로 하면서도, 재판소원의 사유와 기간, 사전심사, 가처분 및 인용효과를 엄격히 제한한 독자적 모델을 취한다. 이를 본고는 제한적 재판소원 모델이라고 부를 수 있다고 본다.

이 모델의 첫 번째 특징은 독립형 헌법재판기관을 통한 기본권구제 구조이다. 한국 헌법은 헌법재판소에 위헌법률심판, 탄핵, 정당해산, 권한쟁의, 헌법소원을 맡기는 집중형 구조를 둔다. 따라서 재판소원도 일반법원의 상소심이 아니라 독립한 헌법재판기관의 헌법심사 절차로 위치한다. 이 구조의 필요성은 헌법재판의 전문성, 헌법질서 수호, 기본권 보장 기능에서 설명된다.[57]

두 번째 특징은 재판소원의 사유열거형 제한이다. 한국법은 법원의 확정재판 일반을 전면적으로 헌법소원의 대상으로 개방하지 않는다. 헌법재판소법 제68조 제3항은 법원의 재판에 대한 헌법소원을 세 가지 사유로 한정한다. 헌법재판소 결정에 반하는 취지의 재판, 적법절차를 거치지 않은 재판, 헌법과 법률 위반으로 기본권 침해가 명백한 재판이 그것이다. 이 구조는 재판소원이 단순한 패소불복절차로 확대되는 것을 막기 위한 첫 번째 문턱이다.

세 번째 특징은 시간적 제한이다. 일반 권리구제형 헌법소원은 그 사유가 있음을 안 날부터 90일, 사유가 있는 날부터 1년 이내에 청구할 수 있다. 그러나 법원의 재판에 대한 헌법소원심판은 그 재판의 확정일부터 30일 이내에 청구하여야 한다. 이 짧은 청구기간은 확정판결의 안정성을 보존하기 위한 핵심 장치일 뿐 아니라, 재판소원과 재심을 구별하는 시간적 표지다. 재심은 법정 재심사유가 문제 될 때 예외적으로 열리지만, 재판소원은 확정 직후 30일이라는 짧은 창을 통해 헌법소원 가능성을 열고 닫는다. 재판소원을 허용하더라도 확정판결이 무기한 불안정한 상태에 놓여서는 안 된다. 따라서 한국법은 확정재판에 대한 헌법적 구제 가능

57) 최희수, “헌법재판의 본질과 헌법재판소의 헌법상 편제”, 『공법학연구』 제9권 제4호, 2008, 179-180면; 손상식, “헌법재판권의 행사 기관에 관한 소고”, 『법학연구』 제26권 제2호, 2018, 147-150면.

성을 인정하면서도, 그 가능성을 일반 헌법소원보다 짧은 기간 내에 행사하도록 제한한다. 이 시간적 자기제한 때문에 재판소원은 재심 일반이나 단순한 확정 후 불복과 구별된다.

네 번째 특징은 사전심사 구조이다. 개정법은 지정재판부가 청구기간 도과, 구제절차 미경유, 재판소원 청구사유의 명백한 부존재 등 일정한 경우 청구를 각하할 수 있도록 한다. 이 사전심사 구조는 한국법의 제한적 재판소원 모델에서 매우 중요하다. 단순히 재판소원이 접수되었다는 사실만으로 확정판결의 효력상태가 달라진다고 보면, 명백히 부적법한 청구나 단순한 패소불복도 확정판결의 안정성을 흔들 수 있다. 사전심사는 이러한 남용 가능성을 통제하고, 유동적 확정의 발생을 적법한 재판소원과 심사가능성이 인정되는 사건으로 한정하는 장치이다.

다섯 번째 특징은 자동정지효의 부정과 가처분의 예외성이다. 한국법은 재판소원 제기 자체에 확정판결의 효력이나 집행력을 정지시키는 효과를 부여하지 않는다. 별도의 가처분 제도를 통하여 필요한 경우에만 효력 또는 집행작용을 잠정적으로 제한할 수 있도록 한다. 이 구조는 재판소원이 상소와 다르다는 점을 분명히 한다. 상소는 확정 전 절차로서 확정을 차단하지만, 재판소원은 확정 후 절차로서 확정판결의 효력을 원칙적으로 유지한다. 다만 예외적으로 가처분이 있는 경우 그 범위에서 효력작용이 조정될 뿐이다.

여섯 번째 특징은 재판취소와 재재판의 결합이다. 재판소원 인용의 효과는 헌법재판소가 해당 재판을 취소하고, 법원이 헌법재판소 결정 취지에 따라 다시 재판하는 구조로 설계되어 있다.[58] 이는 헌법재판소가 법원 재판의 결론을 전면적으로 대체한다는 뜻이 아니다. 헌법재판소는 헌법적 하자를 이유로 해당 재판을 취소하고, 구체적 사건의 재판 기능은 다시 법원으로 돌아간다. 이 구조는 법원의 재판권과 헌법재판소의 기본권보장 기능을 조정하는 방식이다.

이러한 특징들을 종합하면, 한국법은 독일과 일정한 기능적 평행성을 가진다. 독일 재판헌법소원처럼 법원의 재판도 헌법적 심사의 대상이 될 수 있고, 인용 시 재판취소와 환송 또는 재재판 구조가 작동한다. 그러나 한국법은 독일보다 더 명시적인 사유열거 구조를 취한다. 제68조 제3항 각 호 사유, 30일 청구기간, 지정재판부 사전심사라는 장치를 통해 재판소원의 범위를 좁게 설정한다. 따라서

58) 장영수, "규범통제의 본질에 비추어 본 대법원과 헌법재판소의 역할", 『고려법학』 제55호, 2009, 54-56면.

한국법은 독일식 재판헌법소원의 단순한 수입이 아니라, 재판소원의 허용범위를 사유와 절차의 양면에서 제한한 변형모델이다.

미국과의 관계에서는 더 큰 차이가 있다. 미국은 독립형 헌법재판소를 두지 않고, 확정 후 헌법적 구제를 habeas corpus 또는 collateral review 구조 안에서 다룬다. 한국의 재판소원은 그런 의미의 collateral review가 아니다. 다만 미국법은 확정판결 이후의 헌법적 구제를 인정하더라도 직접상소와 구별하고, 절차소진, 기간제한, 반복청구 제한, 심사강도 제한을 통해 확정판결의 안정성을 보호할 수 있다는 기능적 시사를 제공한다. 한국법의 30일 청구기간, 보충성, 사전심사, 심사가능성 기준도 이와 같은 조정의 요청과 같은 방향에 있다.

일본과의 관계에서는 반대 방향의 시사가 있다. 일본식 모델에서는 법원의 확정재판을 독립한 헌법재판기관에 헌법소원으로 가져가는 절차가 존재하지 않는다. 따라서 확정판결의 헌법적 하자는 일반 소송절차와 재심 등 비상구제절차 안에서 처리된다. 이 모델에서는 재판소원이 제기된 확정판결의 효력상태라는 문제가 발생하지 않는다. 반면 한국법은 확정된 재판을 일정한 사유 아래 헌법소원심판의 대상으로 삼았으므로, 일본식 부재 모델과 달리 별도의 효력상태론이 필요하다.

이 지점에서 본고의 유동적 확정 개념이 한국법의 모델적 위치를 설명한다. 한국법은 확정판결을 곧바로 미확정판결로 되돌리지 않는다. 또한 확정판결의 효력을 절대화하여 헌법재판소 결정의 실효성을 무력화하지도 않는다. 적법한 재판소원과 심사가능성이 인정되는 경우, 확정판결의 효력변동 가능성이 헌법재판소 절차 위에 현출되고, 그 효력작용은 가처분 또는 인용결정에 따라 제한적으로 조건화될 수 있다. 이것이 한국형 제한적 재판소원 모델의 핵심이다.

따라서 한국법의 모델적 위치는 세 문장으로 정리할 수 있다. 첫째, 한국법은 재판소원 부재 모델을 떠나 확정재판에 대한 제한적 헌법소원심판을 인정하였다. 둘째, 그러나 그 제도는 전면적 재판헌법소원이 아니라 사유, 기간, 사전심사, 가처분, 재판취소·재재판 구조로 엄격히 제한된 모델이다. 셋째, 이 모델에서 재판소원이 제기된 확정판결의 효력상태를 설명하는 개념이 유동적 확정이다.

이러한 정식화는 재판소원 제도의 양면을 함께 붙든다. 한편으로 재판소원은 헌법재판소 결정의 실효성과 기본권구제를 보장하기 위한 제도이다. 특히 법원의 재판이 헌법재판소 결정에 반하는 취지로 이루어져 기본권을 침해한 경우, 이를 아무런 헌법소송절차 없이 방치한다면 헌법재판의 실효성은 약화된다. 다른 한편으

로 재판소원은 확정판결의 안정성을 쉽게 흔들어서는 안 된다. 확정판결의 권위는 법적 안정성과 분쟁종국성의 기초이고, 사법권 독립의 중요한 요소이기 때문이다.

결국 한국법의 재판소원 제도는 기본권구제와 확정판결 안정성 사이의 절충적 모델이다. 이 절충은 단순한 정치적 타협이 아니라 효력론적 구조를 가진다. 확정은 유지된다. 자동정지효는 없다. 가처분은 예외적으로 작동한다. 인용결정이 있으면 해당 재판이 취소되고 법원의 재재판으로 이어진다. 제3자 관계와 후속 법률관계는 일률적 소급무효가 아니라 시간적·관계적 한정 처리에 따라 조정된다. 이러한 구조 전체를 설명하는 말이 유동적 확정이다.

따라서 비교법 검토의 결론은 다음과 같다. 독일은 재판헌법소원이 4심이 되지 않도록 심사범위와 효과를 제한할 수 있음을 보여준다. 미국은 확정 후 헌법구제가 직접상소와 구별되어야 함을 보여준다. 일본은 재판소원 부재 모델에서는 재심가능성만으로는 유동적 확정과 같은 효력상태가 발생하지 않음을 보여준다. 한국법은 이 세 모델 사이에서, 확정판결의 안정성을 유지하면서도 헌법소송절차에 의한 제한적 효력조정을 허용하는 독자적 위치를 가진다.

이 독자적 위치를 설명하기 위해서는 단순히 재판소원의 허용 여부를 묻는 것만으로는 부족하다. 더 중요한 질문은 재판소원이 제기된 확정판결이 어떤 효력상태에 놓이는가이다. 본고의 유동적 확정 개념은 바로 그 질문에 대한 답이다.

## Ⅵ. 결론

재판소원 제도의 도입은 확정판결 효력론에 새로운 질문을 제기한다. 예전의 쟁점은 법원의 재판을 헌법소원의 대상으로 삼을 수 있는가였다. 그러나 재판소원이 명문화된 뒤에는 질문의 중심이 달라진다. 이제 핵심은 재판소원이 제기된 확정판결이 어떤 효력상태에 놓이는가이다. 본고는 법문상 표현인 “확정된 재판” 또는 “확정재판”을 사용하되, 효력론이 가장 선명하게 드러나는 확정판결을 중심으로 논의를 전개하였다.

본고의 결론은 분명하다. 재판소원이 제기된 확정판결은 미확정판결이 아니다. 재판소원은 확정 전 상소가 아니라 확정 후 헌법소송절차이다. 따라서 재판소원이 제기되었다는 사실만으로 형식적 확정력, 기판력, 집행력이 소멸하지 않는다. 확

정은 유지된다.

그렇다고 그 판결을 통상적 확정판결과 완전히 같게 볼 수도 없다. 적법한 재판소원이 제기되고 심사가능성이 인정되면, 대상 판결은 헌법재판소 절차 위에 놓인다. 그 뒤 가처분이 내려지면 효력 또는 집행작용이 잠정적으로 제한될 수 있고, 본안에서 인용결정이 내려지면 해당 재판은 취소되어 법원의 재재판으로 이어질 수 있다. 이처럼 확정은 유지되지만 효력작용이 헌법소송절차의 결과에 따라 조건화되는 상태가 유동적 확정이다.

유동적 확정은 재심과도 다르다. 재심은 법정 재심사유를 원인으로 법원이 흠 있는 판결 전의 상태로 소송을 돌려 다시 심리할 수 있는 예외적 불복절차이다. 반면 재판소원에서는 제68조 제3항 각 호 사유와 제72조 사전심사를 통과한 확정재판이 헌법재판소의 심판대상으로 놓이고, 가처분 또는 인용결정에 따라 효력작용이 제한적으로 조정될 수 있다. 이 조문상 절차 구조가 유동적 확정의 독자성을 만든다.

또한 유동적 확정은 재판소원을 넓히기 위한 말이 아니다. 오히려 그 반대이다. 유동적 확정은 확정재판성, 적법한 재판소원, 사전심사를 통과할 수 있는 심사가능성이라는 누적요건을 요구한다. 청구기간도 일반 헌법소원보다 짧은 확정일부터 30일로 제한된다. 이 짧은 기간은 확정재판의 헌법소원 가능성을 잠시 열어두되 곧 닫아 절차를 안정시키는 시간적 경계이다. 그러므로 30일 이내와 이후는 동일하지 않다. 기간 내에 적법한 청구와 심사가능성이 결합하면 유동적 확정이 문제 될 수 있지만, 기간이 지나면 청구는 제72조 제3항 제2호에 따라 각하되고 확정판결은 유동적 확정으로 진입하지 못한다. 기간 안의 접수라도 명백히 부적법하거나 제68조 제3항의 청구사유와 무관하면 확정판결의 효력상태를 바꾸지 못한다.

그 효력도 전면적이지 않다. 형식적 확정력은 유지된다. 기판력도 원칙적으로 유지된다. 집행력 역시 자동으로 정지되지 않는다. 다만 가처분이 있으면 그 범위에서 효력 또는 집행작용이 잠정적으로 제한되고, 인용결정이 있으면 해당 재판이 취소되어 재재판 단계로 넘어간다. 제3자 관계와 후속 법률관계는 일률적 소급무효가 아니라 시간적·관계적 한정 처리에 따라 조정되어야 한다.

비교법적으로도 한국법의 위치는 독자적이다. 한국법은 독일식 재판헌법소원을 그대로 수용하지 않았고, 일본식 재판소원 부재 모델에 머물지도 않았다. 미국식 확정 후 부수심사와도 다르다. 한국법은 확정재판을 대상으로 하면서도 사유,

기간, 사전심사, 가처분, 재판취소와 재재판 구조를 결합한 제한적 재판소원 모델을 취한다.

따라서 유동적 확정은 확정판결의 권위를 해체하는 개념이 아니다. 확정판결의 권위를 전제로 하면서, 그 권위가 헌법질서 안에서 어떤 조건 아래 조정될 수 있는지를 설명하는 개념이다. 확정판결의 안정성만을 절대화하면 헌법재판소 결정의 실효성과 기본권구제가 약화된다. 반대로 헌법재판소 결정의 기속력만을 무제한 확장하면 재판소원은 4심으로 변질될 수 있다. 유동적 확정은 이 두 극단을 피하려는 효력조정론이다.

남는 과제도 분명하다. 먼저 제68조 제3항 제1호의 "헌법재판소의 결정에 반하는 취지"를 사건유형별로 정밀화해야 한다. 제2호 적법절차 위반형과 제3호 명백한 기본권 침해형의 세부 기준도 따로 정립해야 한다. 심사가능성의 확인시점 역시 사건유형별로 더 다듬어야 한다.

나아가 가처분의 요건과 효과, 인용결정 후 다시 재판의 절차형식, 재판취소가 형성판결·제3자 관계·이미 완료된 집행·후속 법률관계에 미치는 파급범위도 후속 연구로 남는다. 독일 BVerfGG 제79조에 대응하는 한국법상 명문 한정 규정의 부재도 입법론적으로 검토되어야 한다. 본안 종국판결 외 결정·명령 등 판결 외 재판에 이 분석개념을 적용할 수 있는지도 별도의 과제이다.

투고일: 2026. 05. 12. 심사완료일: 2026. 07. 04. 게재확정일: 2026. 07. 06.

## 【 참고문헌 】

1. 국내문헌

(1) 단행본·실무서

박균성,『행정법강의』제23판, 박영사, 2026.

사법연수원,『법원실무제요 민사소송 I』.

사법연수원,『법원실무제요 민사소송 III』.

법원행정처,『2025 사법연감』, 2025.

(2) 논문

강현중, “기판력에 관한 연구”,『법학논총』제19집, 2007.

강현중, “상소와 재심”,『법학논총』제18집, 2006.

고준성, “변론종결 후 승계인에 대한 신소 제기와 기판력”,『법학연구』제34권 제4호, 2023.

권오걸, “재심과 비상상고의 교차영역”,『법학논고』제81호, 2023.

김상영, “기판력의 작용과 범위의 관계”,『법학연구』제57권 제3호, 2016.

김성혁, “기판력의 객관적 범위와 작용국면으로서의 모순관계 — 소유권이전등기청구소송과 말소등기청구소송을 중심으로”,『법학연구』통권 제67집, 2021.

김시철, “우리 위헌법률심판제도와 헌법재판소 결정의 효력”,『저스티스』제90호, 2006.

김시철, “위헌법률심판절차에서 사법작용의 당부를 심사할 수 있는지(上) — 헌법재판소 2012. 5. 31. 선고 2009헌바123 등 전원재판부 결정에 대하여”,『사법』제21호, 2012.

김시철, “위헌법률심판절차에서 사법작용의 당부를 심사할 수 있는지(下) — 헌법재판소 2012. 5. 31. 선고 2009헌바123 등 전원재판부 결정에 대하여”,『사법』제22호, 2012.

김일룡, “판결주문의 형식과 기판력의 객관적 범위의 관계”,『동아법학』제53호, 2011.

김하열, “헌법재판의 증명책임”, 『헌법재판연구』 제8권 제1호, 2021.
남동현, “판결의 제3자적 효력의 본질과 그밖의 판결의 효력에 관한 검토”, 『비교사법』 제15권 제2호, 2008.
남복현, “법률해석과 관련한 헌법재판소와 대법원의 갈등, 그 원인과 해법 — 대법 2013. 3. 28. 선고 2012재두299 판결을 중심으로”, 『법학논고』 제45집, 2014.
박경철, “우리 헌법질서에서 裁判訴願禁止의 違憲性”, 『공법연구』 제30권 제3호, 2002.
박경철, “법률에 대한 위헌결정의 효력과 헌법소원의 대상이 되는 법원 재판 — 헌재 2022. 6. 30. 선고, 2014헌마760, 2014헌마763 결정에 대한 헌법적 검토”, 『공법연구』 제52집 제2호, 2023.
석현수, “기판력 작용의 요건”, 『한양법학』 제26권 제3집, 2015.
손상식, “헌법재판권의 행사 기관에 관한 소고 — 헌법개정과 관련하여 법원으로부터 독립된 헌법재판기관의 필요성을 중심으로”, 『법학연구』 제26권 제2호, 2018.
손인혁, “동아시아에서 헌법재판의 현황 및 문제점과 그 시사점”, 『저스티스』 통권 제158-2호, 2017.
송승현, “한정위헌결정의 기속력의 인정여부에 대한 대법원과 헌법재판소의 위험한 힘겨루기”, 『법학논총』 제23권 제1호, 2016.
유병현, “화해권고결정의 기판력이 미치는 승계인의 범위와 가처분의 효력 — 대구지방법원 2009. 12. 1. 선고, 2009나2031 판결을 중심으로”, 『저스티스』 통권 제126호, 2011.
이기철, “헌법재판소결정은 주된 이유에도 기속력이 미치는가?”, 『한양법학』 제13집, 2002.
이덕연, “限定違憲決定의 法院에 대한 羈束力 問題”, 『공법학연구』 제12권 제3호, 2011.
이동훈, “헌법재판에서 변형결정의 기속력”, 『공법학연구』 제17권 제2호, 2016.
이준상, “헌법재판에서의 가처분 — 최근 입법논의와 관련하여”, 『사법』 제1권 제13호, 2010.
이지효, “독일 재판소원에서 연방헌법재판소의 개입 기준으로서의 헤크(Heck)

공식”, 『세계헌법재판 조사연구보고서』 2026년 제1호, 헌법재판연구원, 2026.
장영수, “규범통제의 본질에 비추어 본 대법원과 헌법재판소의 역할”, 『고려법학』 제55호, 2009.
조소영, “현행 헌법상 헌법재판제도에 대한 비판적 고찰 — 한정위헌결정에 관한 논쟁을 중심으로”, 『강원법학』 제40권, 2013.
최건호, “확정판결의 반사효와 유사필수적 공동소송”, 『저스티스』 제86호, 2005.
최성호, “재심소송에 있어서 재심사유에 관한 고찰”, 『인권과 정의』 제399호, 2009.
최희수, “헌법재판의 본질과 헌법재판소의 헌법상 편제 — 헌법개정 논의에 부쳐”, 『공법학연구』 제9권 제4호, 2008.
크리스틴느 비께, 남궁술 역, “법에서의 의제(Les fictions en droit)”, 『저스티스』 통권 제134호, 2013.
허완중, “헌법재판소결정의 기속력”, 『헌법판례연구』 제13권, 2012.

(3) 자료

국회 법제사법위원장, “헌법재판소법 일부개정법률안(대안)”, 의안번호 2216845, 2026. 2.
법원행정처, “2025 사법연감 발간”, 보도자료, 2025. 9. 23.
헌법재판소, “권리구제형 헌법소원심판 청구 안내”, 2026.
헌법재판소, “확정된 법원의 재판에 대한 헌법소원심판 도입 안내”, 2026.

<국문요약>

# 재판소원이 제기된 확정판결의 효력에 관한 시론
## — 확정판결을 중심으로 한 '유동적 확정' 개념의 제안 —

김 민 규·박 상 영

2026년 개정 헌법재판소법은 일정한 경우 법원의 확정된 재판에 대한 헌법소원 심판, 이른바 재판소원을 명문화하였다. 개정법은 재판소원의 대상을 "확정된 재판"으로 한정하면서도, 30일 청구기간, 지정재판부 사전심사, 가처분, 재판취소와 법원의 다시 재판 구조를 함께 둔다. 이 조문구조는 하나의 효력론적 긴장을 만든다. 대상은 확정재판이지만, 그 확정재판은 헌법재판소의 제한적 심판대상이 될 수 있고 일정한 경우 효력작용이 정지되거나 재구성될 수 있기 때문이다.

본고는 이 효력상태를 "유동적 확정"으로 설명한다. 유동적 확정이란, 적법한 재판소원과 헌법재판소법 제68조 제3항 각 호 사유의 심사가능성이 인정되는 확정재판이 형식적 확정력, 기판력 등 구속효 및 원칙적 집행력을 유지하면서도, 헌법재판소의 가처분 또는 인용결정에 따라 그 효력작용이 잠정 정지되거나 재판취소 및 법원의 재재판으로 재구성될 수 있는, 효력작용이 조건화된 확정상태를 말한다.

유동적 확정은 재심가능성의 다른 이름이 아니다. 재심은 법정 재심사유와 재심의 소를 전제로 하여 법원이 흠 있는 판결 전의 상태로 소송을 되돌릴 수 있는 예외적 불복절차이다. 반면 재판소원은 확정일부터 30일 이내의 청구, 지정재판부 사전심사, 심판회부결정, 가처분 및 인용 시 재판취소와 다시 재판이라는 헌법재판소법상 구조 위에서 작동한다. 이 30일 청구기간은 일반 권리구제형 헌법소원의 90일·1년 기간과 달리, 확정재판을 장기간 불안정하게 두지 않으려는 단기 안정화 장치이다. 그래서 확정 후 30일 이내와 그 이후는 질적으로 구별된다. 기간 내에는 확정판결의 효력작용이 헌법소원절차로 조건화될 수 있는 시간적 개방성이 있고, 적법한 청구가 사전심사의 문턱을 넘을 수 있을 때 그 개방성은 유동적 확정으로 현출된다.

본고는 헌법재판소법 제68조 제3항 제1호, 즉 법원의 재판이 헌법재판소 결정에 반하는 취지로 이루어져 기본권을 침해한 경우를 중심으로 논의한다. 먼저 1997년 예외적 재판취소 법리와 2022년 기속력 위반형 재판취소 결정이 2026년 재판소원 제도화로 이어지는 흐름을 검토하고, 확정판결의 다층적 효력과 헌법재판소 결정의 기속력이 충돌하는 구조를 효력조정론의 관점에서 분석한다. 이어 유동적 확정의 정의, 발생요건, 효력별 작동, 종료, 재심과의 구별 및 비교법적 시사를 정식화한다.

본고의 결론은 재판소원이 제기된 확정판결은 미확정판결도, 통상적 확정판결도 아니라는 것이다. 유동적 확정은 확정판결의 권위를 해체하는 개념이 아니라, 확정의 유지와 효력작용의 조건화를 병존시켜 재판소원 시대의 확정판결 효력상태를 설명하기 위한 도그마틱적 분석개념이다.

핵심어 : 재판소원, 유동적 확정, 확정판결의 효력, 기판력, 기속력, 재판취소, 가처분, 재재판, 효력조정론, 헌법재판소법 제68조 제3항

<Abstract>

# A Preliminary Study on the Legal Effect of Final Judicial Decisions Subject to Constitutional Complaint

## — Focusing on the Concept of Fluid Finality —

KIM MIN GYU* · PARK SANG YOUNG**

The 2026 amendment to the Constitutional Court Act introduced a constitutional complaint against final judicial decisions in limited circumstances. The amended Act confines such complaints to final decisions of courts, while also providing a thirty-day filing period, preliminary screening by a designated panel, interim measures, annulment of the challenged decision, and retrial by the court in accordance with the Constitutional Court's ruling. This structure creates a doctrinal tension: the challenged decision remains final, yet its legal effects may be suspended or reconstituted through constitutional adjudication.

This article proposes the concept of fluid finality to describe this intermediate legal status. Fluid finality refers to the status of a final judicial decision against which a lawful constitutional complaint has been filed and whose reviewability under Article 68 paragraph 3 of the Constitutional Court Act is not clearly excluded. Such a decision retains formal finality, res judicata or other binding effects, and, in principle, enforceability. At the same time, its operative effects may be conditionally suspended by an interim measure or reconstituted through annulment and subsequent retrial.

* Attorney at Law, Adjunct Professor, KAIST Moon Soul Graduate School of Future Strategy

** Master's Student, Seoul National University School of Law

The article focuses on cases falling under subparagraph 1 of Article 68 paragraph 3, in which a court decision conflicts in substance with a prior Constitutional Court ruling, while leaving the detailed criteria for subparagraphs 2 and 3 to subsequent research. Fluid finality is presented not as a statutory effect but as a doctrinal concept designed to explain the legal status created by the structure of the constitutional complaint procedure. It is not a mere synonym for retrial: retrial presupposes statutory grounds for reopening a final judgment, whereas fluid finality follows from the thirty-day filing period, preliminary screening, referral to the full bench, interim measures, and annulment with subsequent retrial by the court under the amended Constitutional Court Act. The short thirty-day period, compared with the ordinary ninety-day and one-year periods for constitutional complaints under Article 68 paragraph 1, opens only a narrow temporal window for constitutional contestation and reflects the need to stabilize the legal effects of final judicial decisions without undue delay.

Key Words : constitutional complaint against judicial decisions, fluid finality, legal effect of final judgments, res judicata, binding force of Constitutional Court decisions, annulment, interim measures, retrial, theory of effect adjustment, Article 68 paragraph 3 of the Constitutional Court Act